Aktenzeichen:
2 O 229/15

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

(...)
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
(...)

gegen

(...)
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
(...)

Streithelferin:
A

Prozessbevollmächtigte:
(...)

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 2. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht (...), den Richter am Landgericht (...) und den Richter (...) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. September 2016 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

   elektronische Anordnungen mit wenigstens einer Wiedergabeanordnung, einem Controller, vorgesehen um dafür zu sorgen, dass die Wiedergabeanordnung ein rotierendes Menü zeigt, das eine Anzahl Menüoptionen umfasst, wobei dieses Menü in der Wiedergabeanordnung außerhalb der Mitte vorgesehen ist, so dass wenigstens eine Option zu jeder Zeit von der Wiedergabeanordnung weggedreht werden kann, wodurch ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl Optionen zu dem Menü hinzugefügt werden kann,

   - Patentanspruch 1 -

   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   insbesondere wenn das Menü mit einer Perspektive wiedergegeben wird, in der das Menü wie in einer sichtbaren Ebene erscheint, die sich nicht parallel zu dem Schirm erstreckt,

   - Patentanspruch 2 -

   insbesondere wenn die Perspektive durch Änderung entweder der Form oder der Größe wenigstens einer der Menüoptionen erreicht wird.

   - Patentanspruch 13 -

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einer gesonderten und geordneten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben a) und b) unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem

Umfang sie die in vorstehender Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 10. Juli 2013 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in vorstehender Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 10. Juli 2013 entstanden ist und noch entstehen wird.

4. Die Beklagte wird verurteilt,

a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse, soweit diese nach dem 10. Juli 2013 in den Verkehr gebracht wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 697 32 767.1 (deutscher Teil des EP 0 888 687 B1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

b) in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren inländischen Besitz und/oder Eigentum befindliche, vorstehend unter Ziffer 1. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

5. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der durch eine Nebenintervention verursachten Kosten, die der Streithelferin auferlegt werden.

6. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000 € in Ziffer 1 (Unterlassung), in Höhe von 25.000 € in Ziffer 2 (Auskunft/Rechnungslegung), in Höhe von 25.000 € in Ziffern 4.a und b (Rückruf/Entfernung und Vernichtung) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer 5 (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin macht wegen behaupteter Verletzung des Patents EP 0 888 687 Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen geltend und begehrt die Feststellung einer Schadensersatzpflicht. Die Streithelferin ist wegen dieser Vorwürfe auf Beklagtenseite dem Rechtsstreit im Wege der Nebenintervention vor der mündlichen Verhandlung beigetreten.

Die Kammer hat über die Klage gleichzeitig mit der parallelen Verletzungsklage der Klägerin (2 O 263/15) gegen zwei weitere Gesellschaften (aus dem C-Konzern) verhandelt, deren Akte die Kammer beigezogen hat.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Patents EP 0 888 687, welches eine Benutzerschnittstelle mit einer Wiedergabeanordnung zur Wiedergabe von Menüoptionen zum Gegenstand hat. Die Erteilung des am 17. November 1997 (unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 20. Dezember 1996) angemeldeten Patents wurde am 16. März 2005 veröffentlicht. Der deutsche Teil dieses Patents (im Folgenden „Klagepatent") steht unter DE 697 32 767 in Kraft. Der unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents hat - in der Verfahrenssprache - folgenden Wortlaut:

> An electronic device comprising
>
> - at least one display;
> - a controller arranged to cause the display to show a rotating menu comprising a plurality of menu options, which menu is disposed off centre in the display so that at least one option is rotatable off the display at any one time, whereby an arbitrary number of options may be added to the menu without changing its format.

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen, die als Anlage K 3 zu den Akten gereicht wurde.

Das Klagepatent ist u.a. Gegenstand von Nichtigkeitsklagen der Streithelferin und der B sowie der C, wegen deren Inhalts auf die in den Anlagen SH 2, AR 2 und SH 4 vorgelegten Klageschriften sowie die weiteren (auch die im Parallelverfahren 2 O 263/15) zur Akte gereichten Schriftsätze der Nichtigkeitsverfahren wird verwiesen.

Die Nichtigkeitsklagen rügen die fehlende Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen EP 0 626 635 A2 (D 1 bzw. NK 1), EP 0 767 418 A1 (D 2 bzw. NK 2), dem FSN-System (in Gestalt der D 3c bzw. NK 3c), der Lifestreams-Benutzeroberfläche (in mehreren Publikationen in Gestalt der D 4 bzw. NK 4, NK 4a und NK 4b), der WO 96/25747 A1 (D 5 der Nichtigkeitsklage von C) und Menüs auf Playstation-Demo-CDs (wie insbes. aus den Anlagen AR 7 und AR 9 ersichtlich) und aus einem Nintendo 64-Spiel (Schriftsatz vom 5. September 2016, dort S. 2 ff) sowie das Fehlen erfinderischer Tätigkeit. Daneben ist das Klagepatent Gegenstand der in der Anlage SH 4 vorgelegten Nichtigkeitsklage der D.

Die Beklagte vertreibt in Deutschland Mobiltelefone. Die Klage richtet sich gegen solche Geräte der Beklagten, welche mit dem Betriebssystem L ausgestattet sind (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen), insbesondere die Geräte „E", „F", „G", „H".

Dieses Betriebssystem stellt die Funktionalität „K" zur Verfügung, mit der die geöffneten Anwendungen im Überblick angezeigt werden können. Ist eine bestimmte Anzahl von Anwendungen geöffnet, wird ein Teil dieser Anwendungen auf dem Bildschirm als Fenster dargestellt. Hierfür wird auf die Abbildung auf S. 22 der Klageschrift verwiesen. Durch eine Wischbewegung auf dem Display nach oben können die Karten der Anwendungen nach oben verschoben werden, wobei sie irgendwann am oberen Bildschirmrand hinter den vorderen Karten vollständig verschwinden, so dass sie nicht - auch nicht nur teilweise - mehr sichtbar sind. Soweit eine genügende Anzahl von Anwendungen geöffnet ist, rücken dabei entsprechend vom unteren Bildschirmrand Karten geöffneter Anwendungen nach. Durch „Wischen" nach unten kann die Karte der jeweils vordersten Anwendungen am unteren Bildschirmrand aus dem sichtbaren Bereich entfernt werden, wobei die Karten oberhalb dieser Karte nachrücken. Anwendungen, die auf die beschriebene Art und Weise durch Wischen aus dem Display entfernt wurden, treten auch bei Fortsetzen der Wischbewegung nicht irgendwann einmal auf der anderen Seite wieder in das Display ein, sondern können nur durch entgegengesetztes „Wischen" auf derselben Seite, auf der sie durch Wischen entfernt wurden, wieder auf das Display geholt werden.

Die Klägerin bringt vor, die auf den angegriffenen Ausführungsformen implementierte Funktionalität „K" des Betriebssystems L mache von der patentgemäßen Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents unmittelbar Gebrauch.

Insbesondere liege ein anspruchsgemäßes „rotating menu" vor. Die oberen Kanten der gezeigten Karten der geöffneten Anwendungen bewegten sich beim „Wischen" wie auf einem Schaufelrad über das Display, jedenfalls jedoch auf einer Kurve, die der Ausschnitt einer Ellipse sei. Der Patentanspruch fordere nicht, dass sich die Optionen auf einer (scheinbaren) Kreisbahn bewegten. Dem Vorliegen eines „rotating menu" stehe auch nicht entgegen, dass durch „Wischen" auf der einen Seite des Displays entfernte Anwendungen nicht irgendwann auf der anderen Seite wieder auftauchen.

Das Menü der angegriffenen Ausführungsformen sei in der Wiedergabeanordnung außerhalb der Mitte vorgesehen, weil der Punkt, um den sich die Rotation vollziehe, außerhalb der Mitte des Zentrums des Bildschirms liege.

Durch den Versatz des Menüs außerhalb der Mitte könnten Anwendungen auch wie vom Patentanspruch gefordert weggedreht werden.

Hierdurch könnte in Einklang mit der Lehre des Klagepatents ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl von Optionen zu dem Menü hinzugefügt werden. Dass unbegrenzt viele Menüoptionen hinzugefügt werden können, sei nicht erforderlich.

Das Klagepatent werde sich im Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig verweisen.

Die Klägerin hat nach Teilklagerücknahme zuletzt **b e a n t r a g t**:

wie tenoriert, jedoch unter 1. mit „umlaufendes" statt „rotierendes Menü"

Die Beklagten **b e a n t r a g e n**,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise der Beklagten zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden.

Die Streithelferin **beantragt**,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten und ihre Streithelferin bringen vor, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents keinen Gebrauch, wofür sie insbesondere anführen:

Es fehle bereits an einem anspruchsgemäßen „rotating menu". Ein solches setze eine (ggf. nur scheinbare) kreisförmige Bewegung voraus, die zudem jedenfalls den Eindruck eines vollständigen Umlaufs hervorrufen müsse. Dies sei bei den angegriffenen Ausführungsformen jeweils nicht der Fall. Dort bewegten sich die Optionen auf einer logarithmusähnlichen Kurve, die sich gedanklich nicht zu einem Kreis fortsetzen lasse. Die Bewegung der Karten der Anwendungen sei mit dem Stapeln von Karten auf einem Kartenstapel zu vergleichen. Eine Rotation setze im Übrigen voraus, dass herausgedrehte Optionen beim Weiterrotieren irgendwann auf der gegenüberliegenden Seite wieder hineinrotierten.

Auch eine Anordnung des Menüs außerhalb der Mitte könne bereits wegen der logarithmusähnlichen Kurve mangels eindeutiger Menümitte und Rotationsachse, auf deren Versatz gegenüber dem Zentrum des Bildschirms es insoweit ankomme, nicht erkannt werden. Dasselbe gelte im Fall einer Ellipse.

Damit fehle es auch an der beanspruchten Ausgestaltung, bei der gerade wegen eines Versatzes der Menüanordnung aus der Bildmitte wenigstens eine Option weggedreht werden könne. Dieser funktionale Zusammenhang könne bei der (ohnehin offenen und damit unabhängig von einer Anordnung des Menüs außerhalb der Mitte zum Verlassen von Optionen führenden) logarithmischen Kurve nicht erreicht werden. Der Patentverwirklichung stehe auch entgegen, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen der unsichtbare Bereich des Menüs schon durch dessen Dimensionierung erzielt werde.

Zudem ließen sich bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht beliebig viele Optionen hinzufügen, da der K-Screen maximal aus 100 Einträgen bestehe. Dass nach der Lehre des Klagepatents durch das Wegdrehen eine beliebige Anzahl Optionen hinzugefügt werden können müsse, bedeute im Übrigen, dass die weiteren Optionen - anders als bei den angegriffenen Ausführungsformen - im nicht-sichtbaren Bereich hinzugefügt würden. Auch sei das Hinzufügen neuer Optionen bei den angegriffenen Ausführungsformen entgegen der Lehre des Klagepatents mit einer Formatänderung verbunden, weil nicht zur selben Anzeige zurückgekehrt werde. Auch der Umstand, dass bis zu einer bestimmten Anzahl von geöffneten Anwendungen die Darstellungsform des K-Screen beim Öffnen einer weiteren Anwendung geändert werde, stehe der Verwirklichung des Patentanspruchs entgegen.

Die Erhebung von Vernichtungs- und Rückrufansprüchen sei unverhältnismäßig.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

A.

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen Anspruch 1 des Klagepatents (dazu I.) wortsinngemäß (dazu II.). Der Klägerin stehen daher die zugesprochenen Ansprüche zu (dazu III.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits war nicht angezeigt (dazu IV.). Die Kammer folgt damit im Wesentlichen den Erwägungen der 7. Zivilkammer in deren Urteilen vom 26. August 2016 (7 O 240/15 und 7 O 210/15, vorgelegt als Anlage SH 9), welche die Kammer auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Parteien im vorliegenden Rechtsstreit und in den weiteren

Nichtigkeitsklagen, insbesondere deren Auseinandersetzung mit den genannten Urteilen und dem weiteren Vortrag zur Schutzfähigkeit des Klagepatents für zutreffend hält.

I.

Das Klagepatent betrifft eine Benutzerschnittstelle mit zumindest einer Wiedergabeanordnung zur Wiedergabe von Menüoptionen.

Als verwandten Stand der Technik stellt das Klagepatent in Abschnitt [0002] seiner Beschreibung das sog. FSN-System der I vor, bei dem es sich um einen Prototyp handele und das in einem Artikel mit dem Titel „Technology Ready for Prime Time" in J in der Ausgabe vom 26. Dezember 1994, Band 144, beschrieben sei. Nach dem Klagepatent zeigt dieses FSN-System ein „rotating menu" mit Knöpfen, das über den Cursor bewegt wird. Ohne diesen verwandten Stand der Technik an dieser Stelle näher zu würdigen, leitet die Patentbeschreibung in Abschnitt [0003] dazu über, dass Ziel der Erfindung sei, eine verbesserte Benutzerschnittstelle zu schaffen. Dieses Ziel werde erreicht mit einer elektronischen Vorrichtung gemäß dem Patentanspruch 1 (vgl. Abschnitt [0004] der Klagepatentschrift).

Patentanspruch 1 des Klagepatent lautet in einer übersetzten und gegliederten Form wie folgt:

1 Elektronische Anordnung mit

1.1 wenigstens einer Wiedergabeanordnung und

1.2 einem Controller, vorgesehen, um dafür zu sorgen, dass die Wiedergabeanordnung

1.2.1 ein rotierendes Menü (rotating menu) zeigt, das eine Anzahl Menüoptionen umfasst,

1.2.2 wobei dieses Menü in der Wiedergabeanordnung außerhalb der Mitte vorgesehen ist (disposed off centre in the display),

1.2.3 so dass wenigstens eine Option zu jeder Zeit von der Wiedergabeanordnung weggedreht werden kann (rotatable off),

1.2.4 wodurch ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl Optionen zu dem Menü hinzugefügt werden kann.

II.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies steht aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung der Parteien für sämtliche Anspruchsmerkmale mit Ausnahme der Merkmale 1.2.1 bis 1.2.4 außer Streit. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch die streitigen Merkmale.

1. Der K-Screen der angegriffenen Ausführungsformen stellt ein „rotating menu" im Sinne des Merkmals 1.2.1 dar.

a) Nach Merkmal 1.2.1 kommt es darauf an, dass die Wiedergabeanordnung (display) ein „rotating menu" zeigt. Wie sich aus dem Gesamtzusammenhang mit den Merkmalen 1.2.2 und 1.2.3 ergibt, ist dabei nicht vorausgesetzt, sondern sogar ausgeschlossen, dass das Menü vollständig gezeigt wird. Anspruch 1 des Klagepatents bringt es mithin mit sich, dass das „rotating menu" nicht vollständig, sondern nur teilweise gezeigt wird. Ob ein teilweise gezeigtes Menü ein „rotating menu" ist, beurteilt sich demnach nach dem Gesamteindruck, den der gezeigte Ausschnitt auf dem Bildschirm vermittelt. Unerheblich ist, ob das Menü außerhalb des Bildschirms programmiertechnisch als „rotating menu" fortgeschrieben ist. Mit dem Bereich außerhalb des Bildschirms beschäftigt sich der Patentanspruch nicht. Die vorstehende Auslegung ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut des Patentanspruchs, der zum einen darauf abhebt, dass der Controller so eingerichtet ist, dass er bewirkt, dass die Wiedergabeanordnung ein „rotating menu" „zeigt" („*controller arranged to cause the display to show a rotating menu*"), und der sich zum anderen nicht dazu verhält, wie das Menü programmtechnisch für den Bereich außerhalb der Bildschirmanzeige ausgestaltet ist. Dementsprechend führt es auch nicht aus dem Patentanspruch heraus, dass bei den angegriffenen

Ausführungsformen jegliche Bewegung einer Karte stoppen mag, sobald sie aus dem sichtbaren Bereich verschwunden ist. Der Patentanspruch enthält auch keine Festlegungen, wie erreicht werden soll, dass die Bildschirmanzeige ein „rotating-menu" darstellt. Vor diesem Hintergrund ist es unerheblich, dass die Oberkanten der Karten, wie die Beklagtenseite behauptet, bei den Wischbewegungen über den K-Screen mathematisch entlang einer logarithmusähnlichen Kurve geführt werden, und dass Bewegungseffekte durch die perspektivische Verkleinerung der optisch nach hinten rückenden Karten erzielt werden, solange hierdurch der Eindruck eines „rotating menu" hervorgerufen wird.

b) Ein solcher Eindruck wird durch die angegriffenen Ausführungsformen hervorgerufen, wovon sich die Kammer durch die vorgelegten Fotografien des K-Screen, wie etwa aus der im Tatbestand erwähnten Abbildung und aus Anlage K4d, und unabhängig davon durch Inaugenscheinnahme einer angegriffenen Ausführungsform in der mündlichen Verhandlung überzeugen konnte.

Führt man mit dem Finger eine Wischbewegung nach oben aus, drehen sich die Karten in der Wahrnehmung des Betrachters nach hinten. Betrachtet man dabei eine bestimmte Karte, so rückt diese optisch dabei immer weiter nach hinten und es ist immer weniger des oberen Kartenrandes sichtbar, bis sie von den davor angeordneten Karten vollständig verdeckt wird und daher aus dem Sichtbereich verschwindet. Führt man eine Wischbewegung nach unten aus, drehen sich die Karten nach der Wahrnehmung des Betrachters perspektivisch nach vorne. Betrachtet man eine bestimmte Karte, so rückt sie optisch immer weiter nach vorne, wobei ein immer größer werdender Teil dieser Karte gezeigt wird, bis sie am unteren Bildschirmrand nach unten verschwindet. Diese Drehbewegungen reichen aus, um den Eindruck eines „rotating menu" zu vermitteln.

Entgegen der Ansicht der Streithelferin setzt ein patentgemäßes „rotating menu" nicht voraus, dass die Menüoptionen zirkulär um eine gedachte Drehachse rotieren und eine vollständige Drehung ausführen können, so dass weggedrehte Menüpunkte beim Weiterdrehen irgendwann wieder auf dem Display zur Anzeige gelangen.

Es trifft schon nicht zu, dass „*rotating*" zwingend mit umlaufend zu übersetzen wäre, was eine vollständige Drehung implizieren könnte. Vielmehr kann „*rotating*" auch mit drehend/drehbar übersetzt werden. Selbst rotierend bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine vollständige Umdrehung stattfinden muss. Das insoweit als sein eigenes Lexikon maßgebliche Klagepatent selbst verwendet die Wortfamilie *to rotate* nämlich nicht im Sinne einer Rotation um 360°. In Merkmal 1.2.3 heißt es, dass zumindest eine Option „*rotatable off the display*" sein müsse. Im Zusammenhang mit diesem Wegdrehen verbietet sich die Annahme, dass die Wortfamilie *to rotate* mit der Beschreibung einer 360°-Drehung gleichzusetzen sei. Auch der systematische Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs spricht gegen ein Erfordernis eines vollständig umlaufenden Menüs. Wie bereits dargelegt, beschränkt sich der Patentanspruch allein auf Vorgaben für den sichtbaren Bereich, sagt aber nichts zu dem weiteren Schicksal der Optionen nach dem Wegdrehen aus. Soweit in Abschnitt [0008] der Patentbeschreibung das Menü aus Figur 2 als eine Art Karussell („*sort of carousel*") bezeichnet, mag dies zwar implizieren, dass bei diesem Ausführungsbeispiel die weggedrehten Menüoption irgendwann einmal wieder auf der anderen Seite in die Bildschirmanzeige treten. Jedoch handelt es sich um ein bloßes Ausführungsbeispiel. Ein solches Ausführungsbeispiel kann den insoweit weiteren Patentanspruch, in dem eine Beschränkung auf ein vollständig umlaufendes Menü keinen hinreichenden Niederschlag gefunden hat, nicht einschränken.

Dem Klagepatent lässt sich auch nicht entnehmen, dass ein „rotating menu" stets zirkulär bzw. kreisförmig sein müsste. Der Patentanspruch enthält keine solche Einschränkung. Auch dem Begriff *rotating* ist sie nicht immanent, da er auch mit drehbar übersetzt werden kann. Ungeachtet dessen kann der Begriff *rotating*, wie er im Klagepatent verwendet wird, auch nicht dahingehend verstanden werden, dass ein „rotating menu" nur dann vorliegt, wenn es eine feste Rotationsachse bzw. einen Drehpunkt gibt, um die sich die Optionen zirkulär, d.h. mit unveränderlichem Abstand, bewegen. Wie sich aus dem als patentgemäß vorgestellten Ausführungsbeispiel aus Abschnitt [0008] und Figur 2 ergibt, bewegen sich die Menüoptionen dort tatsächlich auf einer Ellipse.

Wollte man dem Begriff *rotating* mithin entnehmen, dass er eine Bewegung um eine Rotationsachse auf einer Kreisbahn voraussetzt, käme es vor dem Hintergrund des Ausführungsbeispiels allenfalls darauf an, ob der Eindruck einer Bewegung um ein Zentrum entsteht. Ein solcher Eindruck entsteht bei den angegriffenen Ausführungsformen, bei denen das Menü nach Auffassung der Kammer den Eindruck eines drehbaren Karteikastens (Rolodex, Rollkartei) erweckt.

Aber selbst wenn man einen anderen Eindruck gewinnen würde, etwa dass auch unter Berücksichtigung der Perspektive die scheinbare Bahn der Oberkanten der Karteikarten nicht kreisförmig, sondern oval ist und sich dementsprechend kein Drehpunkt finden ließe, um den sich die Oberkanten der Karteikarten mit stets gleichem Abstand bewegen, wäre dies unschädlich. Dem Patent geht es darum, eine Darstellungsform für ein „rotating menu" zu finden, die es ermöglicht, wenigstens eine Option aus dem Bildschirm wegzudrehen und beliebige weitere Optionen ohne Formatänderung hinzuzufügen. Hierfür kommt es aus technisch-funktionaler Sicht nicht darauf an, ob das „rotating menu" exakte Kreisform oder eine abgeflachte, etwa ovale Form hat. Entscheidend ist vielmehr, dass der Eindruck entsteht, dass sich die Optionen um einen zentralen Punkt bewegen. Dies ist aber auch dann der Fall, wenn die Form des Menüs nicht exakt einer Kreisbahn, sondern einem Oval entspricht. Soweit die Parteien Erwägungen zu einer Drehachse bzw. einem Drehpunkt anstellen, verkennen sie, dass das Klagepatent keine geometrisch exakten Gebilde anspricht und auch keine Vorgaben dazu macht, wie etwas mathematisch exakt zu implementieren wäre. Das Klagepatent betrifft vielmehr eine bestimmte Art der Bildschirmdarstellung, die einen bestimmten Effekt erzielen soll, nämlich dass wenigstens eine Option von der Wiedergabeanordnung weggedreht und hierdurch ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl von Menüs hinzugefügt werden kann. Bereits dies offenbart dem Fachmann, dass es dem Klagepatent nicht um eine physikalisch oder mathematisch exakte Begrifflichkeit geht, etwa dahin, dass nur Drehungen im physikalisch-mathematischen Sinne, bei denen sich die einzelnen Punkte mit stets gleichem Abstand um eine feste Drehachse bzw. einen Drehpunkt drehen, eine Drehung bzw. Rotation im Sinne des Klagepatents sind.

Soweit die Klagepatentschrift in Abschnitt [0011] von einem „*apparent circle*" spricht und auch die Figuren jedenfalls scheinbar kreisförmige Menüs zeigen, handelt

es sich um Ausführungsbeispiele, die den aus dem technisch-funktionalen Verständnis gewonnenen weiteren Sinngehalt des Patentanspruchs nicht einzuschränken vermögen.

c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das Klagepatent das Menü des sog. FSN-Systems, das es als einzigen verwandten Stand der Technik vorstellt, in Abschnitt [0002] der Patentbeschreibung als „rotating menu" bezeichnet und dieses ein zirkuläres, 360° umlaufendes Menü darstellt. Zwar handelt es sich bei dem Stand der Technik um zulässiges Auslegungsmaterial, aus dem der Fachmann ggf. auch die Definition eines bestimmten Begriffes der Patentschrift entnehmen kann. Es ist indes schon nicht ersichtlich, dass das Klagepatent das Menü des FSN-Systems als gattungsbildend ansehen würde und auf Menüs dieser Art beschränkt wäre. Die Beklagtenseite hat auch nicht aufgezeigt, dass der Begriff „rotating menu" bereits in der Veröffentlichung zum FSN-Menü (Anlage D 3a zur Nichtigkeitsklage gemäß Anlage SH 2), welche in Abschnitt [0002] der Patentbeschreibung in Bezug genommen wird, als feststehender Begriff verwendet wird. Die Streithelferin verweist sogar selbst darauf, dass in der genannten Veröffentlichung das FSN-Menü als „*revolving carousel*", also mit einer anderen Begrifflichkeit bezeichnet ist. Erst Recht hat die Beklagtenseite nicht aufgezeigt, dass der Begriff „rotating menu" in der genannten Veröffentlichung als Definition im Sinne der Beklagtenseite verwendet wird. Es kann daher offenbleiben, ob ein Presseartikel (nichts anderes stellt die in Bezug genommene Veröffentlichung dar) für einen Fachmann überhaupt ein Medium sein kann, aus dem er die Definition eines Anspruchsmerkmals entnehmen würde. Es verbleibt mithin allein der Umstand, dass die Patentschrift in Abschnitt [0002] der Patentbeschreibung erwähnt, dass das FSN-System ein „rotating menu" zeige. Aus dieser Erwähnung kann indes in Ermangelung weiterer Anhaltspunkte nicht gefolgert werden, dass damit eine abschließende Definition des „rotating menu" in dem Sinn aufgestellt würde, dass nur Menüs, die denen des FSN-Menüs exakt entsprechen, patentgemäß wären, und mit dem Verweis auf das FSN-Menü nicht lediglich beispielhaft ein Menü vorgestellt werden sollte, das zwar vom Begriff „rotating menu" umfasst ist, auf das dieser Begriff jedoch nicht beschränkt ist. Aus denselben Gründen kann auch nicht gefolgert werden, dass allein die Fortbildung von Menüs,

die denen aus dem sog. FSN-System entsprechen, Gegenstand des Klagepatents wäre.

d) Unschädlich ist auch, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen die Rotationsebene nicht parallel zum Bildschirm oder in einem spitzen Winkel zur Bildschirmebene verläuft, so dass der Eindruck entsteht, dass die Rotationsebene im Bildschirm liegt, sondern in einem Winkel von 90 Grad zur Bildschirmebene steht. Weder der Patentanspruch noch die Patentbeschreibungen machen Vorgaben zur Lage der Rotationsebene. Soweit bei der Beschreibung der Ausführungsbeispiele Rotationsebenen und deren Lage angesprochen sind (vgl. Abschnitt [0008]), handelt es sich wiederum lediglich um Ausführungsbeispiele, auf die der Patentanspruch nicht beschränkt werden kann. Der Patentanspruch setzt nämlich lediglich voraus, dass das „rotating menu" teilweise im Bildschirm gezeigt wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Bereich, in dem die Menüpunkte ihre Bewegung vollziehen, senkrecht auf der Bildschirmebene steht. Denn auch in diesem Fall zeigt der Bildschirm ein sich drehendes Menü, nämlich ein Menü, dessen Elemente sich perspektivisch gesehen von vorne nach hinten bewegen und dabei den Eindruck einer Drehbewegung erwecken.

2. Der K-Screen der angegriffenen Ausführungsformen stellt überdies ein „rotating menu" dar, welches in der Wiedergabeanordnung außerhalb der Mitte vorgesehen ist („*which menu is disposed off centre in the display*"), Merkmal 1.2.2.

a) Dies ist nach Auffassung der Kammer immer dann der Fall, wenn das Menü aus dem Zentrum verschoben bzw. versetzt, also nicht zentriert ist. Dabei kommt es nicht auf die Positionierung einer (rechnerischen) Kurve, auf deren Grundlage die Bildschirmdarstellung berechnet werden mag, sondern auf die Positionierung des - nicht vollständig gezeigten - „rotating menu" selbst, dessen Eindruck beim Betrachter durch die Darstellung erweckt wird, an. Denn der Patentanspruch hebt darauf ab, dass (und wie) ein „rotating menu" „gezeigt" wird.

In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, wo bei den angegriffenen Ausführungsformen eine Drehachse bzw. ein Drehpunkt/-zentrum liegt. Der Patentanspruch hebt nicht auf eine bestimmte Beziehung von Drehachse/Drehpunkt und Zentrum des Bildschirms ab, sondern fordert schlicht,

dass das „rotating menu" aus dem Zentrum versetzt sein muss. Auf welche Weise dieser Versatz realisiert wird, legt der Patentanspruch nicht fest. Eine Drehachse oder einen Drehpunkt erwähnt er nicht einmal.

Der vorstehende Befund wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass es bei der Beschreibung der Ausführungsbeispiele (dort in Abschnitt [0011]) heißt, dass der Mittelpunkt des scheinbaren Kreises auf dem Bildschirm aus der Mitte versetzt liegt. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass diese Beschreibung eines Ausführungsbeispiels eine allgemeine Definition beinhalten würde, was „*disposed off centre*" voraussetzt, nämlich dass ein Mittelpunkt eines scheinbaren Kreises nicht in der Mitte des Bildschirms liegt. In Abschnitt [0011] wird nur anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben, wie das Merkmal „*disposed off centre*" realisiert werden kann. Der Patentanspruch stellt wie dargelegt nicht auf die räumliche Lage des Mittelpunktes eines scheinbaren Kreises im Vergleich zum Mittelpunkt des Bildschirms ab. Es bleibt damit dabei, dass die Beschreibungsstelle lediglich ein mögliches Beispiel für eine Ausführungsform beschreibt, in der Merkmal 1.2.2 verwirklicht ist, ohne das Merkmal auf diese Art seiner Verwirklichung zu beschränken. Darauf, dass es das einzige Ausführungsbeispiel ist, das Merkmal 1.2.2 beschreibt, kommt es nicht an.

b) Bei den angegriffenen Ausführungsformen ist das Menü bei dieser Auslegung im Sinn des Patentanspruchs außerhalb der Mitte vorgesehen.

Dabei ist es nach der oben gefundenen Auslegung unschädlich, wenn sich die Oberkanten der Karten bei den angegriffenen Ausführungsformen auf einer logarithmusähnlichen Kurve durch den sichtbaren Bereich des Bildschirms bewegen sollten und für diese logarithmische Kurve kein (eindeutiger) Drehpunkt definiert werden kann. Denn auf die Lage einer Drehachse oder eines Drehpunkts kommt es wie ausgeführt nicht an. Auch kommt es nicht darauf an, wie sich die Bewegung mathematisch exakt beschreiben lässt, sondern welchen Eindruck die Bewegung vermittelt.

Bei dem K-Screen entsteht der Eindruck, dass sich die sichtbaren Karten - wie bereits dargelegt - um ein Zentrum drehen und dass das somit (teilweise) gezeigte „rotating menu" aus dem Zentrum des Bildschirms versetzt ist. Es ist nämlich nur ein Teil des Menüs zu sehen, so dass das Menü zwangsläufig aus der Bildschirmmitte

verschoben ist. Ergänzt man gedanklich den gezeigten Menüausschnitt zu einem vollständigen Menü, erhält man eine Art drehbaren Karteikasten oder ein ovales Rad. Um ausgehend von einem vollständig gezeigten zentrierten Menü den auf den angegriffenen Ausführungsformen gezeigten Ausschnitt zu erhalten, muss man das Menü nach unten verschieben und vergrößern. Diese Vergrößerung führt dabei nicht aus Merkmal 1.2.2 hinaus, da der Patentanspruch eine Vergrößerung nicht verbietet. Soweit Merkmal 1.2.4 eine Formatänderung verbietet, bezieht sich dies lediglich auf die Situation, in der bereits das versetzte, teilweise Menü vorliegt und weitere Menüpunkte hinzugefügt werden sollen.

c) Selbst wenn man aber auf ein Drehzentrum bzw. Menüzentrum abstellen und dieses mit der Bildschirmmitte vergleichen wollte, läge bei den angegriffenen Ausführungsformen ein solcher Punkt nicht in der Bildschirmmitte, sondern unterhalb der Mitte der Bildschirmebene und perspektivisch nach hinten versetzt. Die perspektivische Versetzung in die Tiefe führt nicht aus dem Patentanspruch hinaus, selbst wenn man ihn dahingehend auslegen wollte, dass ein Abgleich zwischen Drehpunkt und Bildschirmmitte vorzunehmen ist, denn auch bei dieser Auslegung würde er eine zusätzliche Verschiebung in die Tiefe nicht ausschließen. Bei dieser Auslegung wäre es auch unschädlich, wenn der Drehpunkt projiziert auf die Ebene des Bildschirms außerhalb des sichtbaren Bereichs läge, denn Merkmal 1.2.2 fordert nur, dass das Menü teilweise im Bildschirm liegt, nicht jedoch, dass das auch für einen Drehpunkt oder die Menümitte gilt. Eine solche weitere Einschränkung lässt sich auch Abschnitt [0011] nicht entnehmen. Zwar könnte sich dieser Abschnitt so lesen lassen, dass die Mitte des scheinbaren Kreises auf dem Bildschirm liegen müsse, jedoch handelt es sich um ein Ausführungsbeispiel, auf das der Patentanspruch, der sich nicht mit der Lage des Menümittelpunkts in Bezug auf den dargestellten Bildschirm befasst, nicht beschränkt werden kann.

3. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch Merkmal 1.2.3.

a) Merkmal 1.2.3 steht in funktionalem Zusammenhang mit Merkmal 1.2.2 und fordert, dass die Verschiebung im Sinne des Merkmals 1.2.2 zur Folge hat, dass wenigstens eine Option zu jeder Zeit von der Wiedergabeanordnung weggedreht werden kann („*so that at least one option is rotatable off the display at any one time*").

Der Versatz des Menüs muss mithin Mittel sein, um das Wegdrehen zu ermöglichen. Auch das Wegdrehen („*rotatable off*") erfordert keine zirkuläre Bewegung. Denn wie dargelegt sind nicht nur (scheinbar) zirkuläre Menüs patentgemäß.

Der Patentanspruch schließt es auch nicht aus, dass eine patentgemäße Vorrichtung neben der patentgemäßen Anzeige eines „rotating menu" weitere Menüanordnungen erzeugen kann, die nicht patentgemäß sein mögen. So ist auch eine Ausgestaltung patentgemäß, die von der Lehre des Klagepatents erst ab einer bestimmten Anzahl von Optionen Gebrauch macht. Der Patentanspruch setzt lediglich voraus, dass der Controller so eingerichtet ist, dass er die Anzeige eines patentgemäßen Menüs herbeiführt. Dass er daneben noch auf andere Art und Weise betrieben werden kann, schließt eine Patentverletzung nicht aus (vgl. BGH, GRUR 2009, 399 - Rangierkatze). Dem steht nicht das Untermerkmal „zu jeder Zeit" entgegen. Dies bedeutet lediglich, dass bei einer patentgemäßen Menüanordnung wenigstens eine Option zu jeder Zeit weggedreht werden können muss und nicht, dass jede Menüanordnung, die bei den angegriffenen Ausführungsformen neben der patentgemäßen benutzt wird, patentgemäß ausgestaltet sein müsste.

Der funktionale Zusammenhang zwischen dem Versatz des Menüs und der Möglichkeit des Wegdrehens ist bereits dann gegeben, wenn in der konkreten Darstellung des Menüs auf dem Bildschirm der Versatz bewirkt, dass die wenigstens eine Option weggedreht werden kann. Dabei muss es sich aber nicht um eine notwendige Bedingung handeln. Weder der Anspruchswortlaut noch das in der Beschreibung und den Figuren erläuterte Wirkprinzip der Erfindung schließen es aus, dass es ohne den Versatz hypothetische Ersatzursachen für ein Verschwinden von Optionen beim Drehen gäbe. Dies gilt jedenfalls, wenn die Wegdrehbarkeit ohne den Versatz nicht in genau derselben Weise gegeben ist. Vielmehr gebieten Anspruchswortlaut und sonstiger Inhalt der Patentschrift ein Verständnis, wonach es jedenfalls genügt, wenn der Versatz hinreichende Bedingung für die Wegdrehbarkeit, also so groß gewählt ist, dass eine Wegdrehbarkeit zumindest wegen dieses Versatzes garantiert ist und die konkrete Ausgestaltung des Wegdrehens auf der Positionierung des Menüs außerhalb des Zentrums beruht. Unschädlich ist es daher, wenn das „rotating menu" so groß dimensioniert ist, dass es schon wegen seiner

Größe nicht gänzlich auf dem Bildschirm dargestellt werden könnte und daher auch ohne den Versatz Optionen den sichtbaren Bereich verlassen könnten, oder wenn wegen Menübahn und perspektivischer Darstellung auch ohne den Versatz Optionen durch das Menü selbst verdeckt werden könnten.

b) Bei den angegriffenen Ausführungsformen ist dieses Merkmal erfüllt.

Im K-Screen kann jederzeit im Sinn des Merkmals 1.2.3 wenigstens eine Menüoption weggedreht werden, nämlich (nur) durch das Entfernen der Karte nach unten. Dabei handelt es sich auch um eine Drehbewegung, da das angezeigte Menü, so wie es sich dem Betrachter darstellt, eine Drehbewegung durchführt. Vor diesem Hintergrund ist es unschädlich, dass die vorderste Karte unmittelbar vor ihrem Verschwinden im Wesentlichen eine Bewegung nach unten vollführen mag, zumal sie, um zum Verschwinden gebracht zu werden, zunächst einmal in diese Position gedreht werden muss. Sind bei den angegriffenen Ausführungsformen ausreichend viele Anwendungen geöffnet, verändert sich nämlich die Anzahl der angezeigten Karten nicht mehr und es kann zu jeder Zeit die vorderste Karte nach unten vom Bildschirm weggedreht werden. Dass dies voraussetzt, dass eine bestimmte Anzahl von Anwendungen geöffnet ist, ist nach dem Vorstehenden unschädlich.

Diese Möglichkeit des Wegdrehens erfüllt auch den funktionalen Zusammenhang zwischen dem Versatz des Menüs und dem Wegdrehen. Durch den oben beschriebenen Versatz nach unten ist eine zumindest hinreichende Bedingung dafür gesetzt, dass das „rotating menu" nicht vollständig zu sehen ist und damit Optionen den sichtbaren Bereich verlassen können. Dem funktionalen Zusammenhang steht nicht entgegen, dass Karten auch bei einer Anordnung des Menüs vollständig im sichtbaren Bereich unsichtbar werden könnten, indem sie bei einer Drehung auf die vom Betrachter abgewandte Seite des Rades von demselben verdeckt würden. Ein solches Wegdrehen wäre kein Wegdrehen im Sinne des Klagepatents. Bereits aus dem Wortlaut des Patentanspruchs folgt, dass ein Wegdrehen aus dem sichtbaren in einen auf dem Bildschirm befindlichen verdeckten Bereich nicht genügt, denn dort wird explizit auf ein *„rotatable off the display"* abgestellt. Mit *display* ist dabei, wie sich aus Merkmal 1.1 ergibt, die Vorrichtung *display* und nicht etwa ein sichtbarer Bereich auf dieser Vorrichtung gemeint.

„*Rotatable off the display*" meint daher, dass die Option seitlich, oben oder unten die gezeigte Bildschirmebene verlassen muss. Für dieses Verständnis spricht auch der Zusammenhang mit Merkmal 1.2.2. Demnach zielt der Versatz aus der Mitte gerade darauf ab, ein Wegdrehen zu ermöglichen, was zwanglos bedeutet, dass ein Wegdrehen über die Bildschirmränder hinaus vorliegen muss.

Aber selbst wenn man auch das Drehen in einen nicht-sichtbaren Bereich des Bildschirms als patentgemäß ansehen wollte, wäre jedenfalls die konkrete Ausgestaltung des Wegdrehens bei den angegriffenen Ausführungsformen erst durch den Versatz des Menüs ermöglicht, was bei zutreffender Auslegung des Patentanspruchs genügt. Dessen Verwirklichung steht aus demselben Grund auch nicht entgegen, dass das „rotating menu" des K-Screens, so wie es sich dem Betrachter darstellt, bei gedachter Vervollständigung des Rades selbst im Fall einer zentrierten Anordnung nicht vollständig auf den Bildschirm passen mag. Denn unabhängig davon beeinflusst der Versatz aus der Mitte jedenfalls die konkrete Stelle, an der das Wegdrehen erfolgt und stellt eine hinreichende Bedingung zur Ermöglichung eines Wegdrehens dar.

4. Der K-Screen realisiert auch Merkmal 1.2.4.

a) Dieses Merkmal lehrt einen funktionalen Zusammenhang dahin, dass aufgrund der Möglichkeit des Wegdrehens wenigstens einer Option ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl Optionen hinzugefügt werden können muss.

Merkmal 1.2.4 beschreibt damit eine bloße Eignung. Es erfordert nicht, dass tatsächlich eine beliebige Anzahl Optionen hinzugefügt wird. Dies ergibt sich bereits aus seinem Wortlaut. Dass eine beliebige Anzahl hinzugefügt werden kann, bedeutet nicht, dass eine unbegrenzte Anzahl hinzugefügt können werden muss. Ein technisches Gerät hat schon denklogisch immer eine Begrenzung, die letztlich durch den begrenzten Speicher vorgegeben ist. Eine Grenze ist daher unschädlich. Dass die Anzahl beliebig ist, bedeutet allein, dass nicht von vorneherein eine bestimmte Anzahl aufgrund der Form des Menüs festgelegt ist. Es müssen mehr, genauso viele oder weniger Optionen ohne Formatänderung hinzugefügt werden können, als man erwarten würde, wenn man den sichtbaren Teil des Menüs gedanklich fortsetzt und ausgehend von den sichtbaren Optionen auf die Gesamtzahl der Optionen

hochrechnet. Weder bei weniger noch bei mehr als den erwarteten Optionen darf das Format des Menüs nach der patentgemäßen Lehre angepasst werden, etwa durch Verkleinerung oder Vergrößerung der Optionssymbole oder des Umfangs des Menüs.

Das Merkmal 1.2.4 fordert nicht - auch nicht in seinem systematischen Zusammenhang mit den Merkmalen 1.2.3 und 1.2.2 -, dass die weiteren Optionen im nicht-sichtbaren Bereich hinzugefügt werden. Auf welche Art und Weise die beliebig vielen weiteren Optionen hinzugefügt werden, legt der Anspruch nicht fest. Nach dem Patentanspruch muss vielmehr die Wegdrehbarkeit im Sinn des Merkmals 1.2.3 lediglich ermöglichen, dass eine beliebige Anzahl weiterer Optionen zu dem Menü ohne Formatänderung hinzugefügt werden kann. Dies ist aber auch dann gegeben, wenn die weitere Option im sichtbaren Bereich erscheint und dafür eine andere vorher angezeigte Option aus dem sichtbaren Bereich verschwindet. Auch in diesem Fall ist die Wegdrehbarkeit Grund dafür, dass das Format des Menüs und dessen Beibehaltung nicht die Anzahl der möglichen Optionen determiniert, weil das Menü eben nicht vollständig gezeigt wird, sondern beim Drehen Optionen aus dem sichtbaren Bereich verschwinden. Es ist auch nicht erforderlich, dass eine weitere Option nach ihrem Hinzufügen erst in den sichtbaren Bereich gedreht werden muss, um auf sie zugreifen zu können. Auch die Patentbeschreibung enthält keine solche Beschränkungen.

Ebenso wenig ist zu fordern, dass das Hinzufügen gerade durch das Wegdrehen bewirkt wird. Nach dem maßgeblichen Wortlaut des Patentanspruchs ist die Wegdrehbarkeit Mittel dazu, ein Hinzufügen (wo auch immer) zu ermöglichen, nicht um es tatsächlich herbeizuführen. Mit anderen Worten wird durch den Versatz des Menüs aus der Bildschirmmitte und durch die Eignung zum Wegdrehen eine Darstellungsform erreicht, die es - anders als bei einem zentrierten vollständig im Bildschirm gezeigten Menü - hinreichend ermöglicht, ohne Formatänderung im sichtbaren Bereich beliebig viele weitere Optionen hinzuzufügen. Entscheidend ist dabei der Wirkzusammenhang zwischen den Merkmalen, die aufeinander aufbauen. Zunächst muss das Menü versetzt sein. Das reicht aber noch nicht aus. Vielmehr muss der Versatz dergestalt sein, dass er eine Wegdrehbarkeit mindestens einer Option aus dem Bildschirm garantiert. Diese Wirkungskette bewirkt patentgemäß die

Möglichkeit, dass eine beliebige Anzahl weiterer Optionen ohne Formatänderung hinzugefügt werden kann, weil hierdurch nur ein Teil des „rotating menu" gezeigt wird und damit keine Restriktionen aufgrund der (gedanklichen) Form des „rotating menu" bestehen. Einen Wirkzusammenhang zwischen dem Wegdrehen und dem Hinzufügen (statt zwischen dem Wegdrehen und der bloßen Ermöglichung des Hinzufügens) beschreibt der Patentanspruch nicht. Auch aus der Patentbeschreibung lässt sich nichts Abweichendes entnehmen. Insbesondere beschreibt auch Abschnitt [0011], der als Darstellung eines Ausführungsbeispiels den Patentanspruch ohnehin nicht entgegen seinem Sinngehalt beschränken könnte, lediglich einen Wirkzusammenhang zwischen dem Wegdrehen und der Möglichkeit des Hinzufügens einer beliebigen Anzahl weiterer Optionen ohne Formatänderung und nicht etwa einen Wirkzusammenhang zwischen Wegdrehen und dem tatsächlichen Hinzufügen.

Ebenso wenig muss das Hinzufügen einer Option dazu führen, dass eine andere Option weggedreht wird. Der Patentanspruch fordert nur, dass das Hinzufügen ohne Formatänderung erfolgen können muss. Wie dies bewerkstelligt wird, insbesondere ob dies dadurch geschieht, dass eine andere bisher gezeigte Option im Sinne des Merkmals 1.2.3 aus dem Bildschirm weggedreht wird, oder dadurch, dass diese auf andere Weise verschwindet, lässt der Patentanspruch offen.

Ferner schreibt der Patentanspruch auch nicht vor, dass ein Hinzufügen von weiteren Optionen von der Menüansicht selbst aus vorgenommenen werden müsste. Weder der Patentanspruch noch die Patentbeschreibung enthalten eine solche Festlegung. Von wo aus das Hinzufügen erfolgt, wer es vornimmt etc., dazu enthält das Patent keine Vorgabe. Der Patentanspruch formuliert passivisch („*may be added*"). Entscheidend ist allein, dass die patentgemäße Lehre eine Darstellungsform zur Verfügung stellt, bei der durch den Versatz des „rotating menu" und die hierdurch herbeigeführte Wegdrehbarkeit mindestens einer Option aus dem Bildschirm eine beliebige Anzahl weiterer Optionen ohne Formatänderung hinzugefügt werden kann.

Soweit der Anspruch ein Hinzufügen ohne Formatänderung fordert, bezieht sich dies auf eine Änderung des Formats des Menüs. Dieser Bezugspunkt ergibt sich aus dem maßgeblichen Wortlaut des Anspruchs in der Verfahrenssprache, wo es

heißt, dass eine beliebige Anzahl von Optionen „*may be added to the menu without changing its format*." Das Possessivpronomen „*its*" bezieht sich eindeutig auf das Menü. Da sich der Patentanspruch wie dargelegt nicht mit dem befasst, was außerhalb des auf dem Display angezeigten Bereichs geschieht, meint der Patentanspruch Formatänderungen des auf dem Bildschirm gezeigten Teils des Menüs, also im sichtbaren Bereich. Bestätigt wird dies durch die funktional-technische Betrachtungsweise, dass es dem Klagepatent gerade darum geht, Formatänderungen im sichtbaren Bereich zu verhindern. Auch aus der Beschreibung des Klagepatents lässt sich nichts Abweichendes entnehmen. Unter Format im Sinne des Patentanspruchs ist dabei das Layout des Menüs, insbesondere die Größe des Menüs selbst - auch wenn sich die davon zu unterscheidende Größe der Darstellung von einzelnen Menüoptionen beim Ortswechsel durch Drehen durchaus zur Darstellung einer Perspektive ändern mag, vgl. Unteranspruch 13 - und die Anzahl der gezeigten Optionen zu verstehen. Das Layout darf nicht von der Anzahl der Optionen des Menüs abhängen. Keine Formatänderung in diesem Sinne ist es, wenn sich der Inhalt bzw. die Belegung eines Optionssymbols ändert. Mit dem Inhalt einzelner Optionen oder ihrer Reihenfolge befasst sich der Patentanspruch nicht. Auch die Beschreibung enthält insoweit keine Einschränkung. Im Gegenteil: In Abschnitt [0011] der Patentbeschreibung wird auf die Form der Bildschirmanzeige des Menüs („*shape of the display*"), die durch das Hinzufügen weiterer Optionen nicht negativ beeinflusst werden soll, und auf die Vermeidung einer Verkomplizierung des Bildschirms abgehoben. Angesprochen sind damit die Fälle, in denen das Hinzufügen weiterer Optionen nur dadurch möglich wird, dass der Umfang des „rotating menu" vergrößert oder die Optionssymbole verkleinert werden. Auch die Figuren der Klagepatentschrift befassen sich nicht mit der Belegung der einzelnen Optionssymbole. Sie zeigen nur ihre Anzahl und ihre Form/Größe. Dem Klagepatent geht es nur darum, eine verbesserte Darstellungsform für ein Menü zu finden, die das Hinzufügen weiterer Optionen ohne Formatänderung ermöglicht. Mit der Belegung der einzelnen Optionssymbole befasst sich die Lehre nicht.

b) Vor diesem Hintergrund ist Merkmal 1.2.4 durch die angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht. Durch den Versatz des Menüs aus dem Zentrum des Bildschirms und die hierdurch bewirkte Wegdrehbarkeit einzelner Karten können

bei den angegriffenen Ausführungsformen neue Optionen ohne Formatänderung des Menüs hinzugefügt werden. Wird nämlich eine neue Anwendung geöffnet, wird dessen Karte am unteren Bildschirmrand angezeigt, ohne dass sich das Format des K-Screen ändert, nämlich ohne dass sich die Anzahl der angezeigten Optionen oder die Größe des gezeigten Menüs ändert. Dies ist - jedenfalls hinreichend - möglich, weil das Menü nicht zentriert ist und aufgrund der damit einhergehenden Wegdrehbarkeit einzelner Optionen ein nicht-sichtbarer Bereich des Menüs besteht, wodurch dem Menü beliebig viele Optionen hinzugefügt werden können, ohne dass hierfür das Format des angezeigten Teilmenüs geändert wird.

Nach dem oben dargelegten Verständnis ist es für die Verwirklichung des Merkmals 1.2.4 unschädlich, dass der Benutzer der angegriffenen Ausführungsformen eine weitere Option dem K-Screen nur hinzufügen kann, indem er diesen verlässt und eine neue Anwendung öffnet, die dann beim Wiederaufruf des K-Screens als vorderste Karte auf dem K-Screen angezeigt wird. Wie dargelegt, fordert der Anspruch nicht, dass die weitere Option während der ununterbrochenen Anzeige des Menüs hinzugefügt können werden muss, dass das Hinzufügen durch das Wegdrehen verursacht sein muss oder dass das Hinzufügen im nicht-sichtbaren Bereich erfolgen müsste. Dass durch das Öffnen einer weiteren Anwendung und das Hinzukommen ihrer Karte am unteren Bildschirmrand keine der bisher gezeigten Karten aus dem Bildschirm im Sinne des Merkmals 1.2.3 weggedreht wird, sondern auf andere Weise verschwindet, ohne dass das Format des Menüs durch das Hinzufügen geändert wird, steht der Nutzung der patentgemäßen Lehre nach dem Vorstehenden ebenfalls nicht entgegen. Ebenso führt es nicht aus dem Patentanspruch hinaus, dass nach dem Öffnen einer weiteren Anwendung und dem Wiederaufruf des K-Screen nunmehr die neue Anwendung als erste Karte und danach die Karten der aktuell zuletzt verwendeten Anwendungen gezeigt werden, die nicht identisch mit den Anwendungen sein müssen, die beim letzten Aufruf des K-Screens die zuletzt benutzten und damit angezeigten Anwendungen waren. Diese andere Anzeige betrifft nicht das Format des Menüs (Größe des gezeigten Menüs und Anzahl der gezeigten Optionen), sondern lediglich den Inhalt der gezeigten Optionen. Wie bereits ausgeführt, führt es auch nicht aus der Verletzung heraus, dass sich das Format des K-Screens durch Öffnen einer weiteren Anwendung erst

dann nicht mehr ändert, wenn eine bestimmte Anzahl von Anwendungen offen ist, aber zuvor das Öffnen einer weiteren Anwendung einen Übergang zu einer anderen Darstellungsform bewirkt. Das Patent fordert lediglich, dass der Controller so eingerichtet sein muss, dass er die patentgemäße Lehre nutzt. Es verbietet es nicht, dass es noch andere Darstellungsformen von Menüs gibt, die nicht patentgemäß sind.

III.

Nach alledem sind die Klageanträge aufgrund der wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen im zuletzt aufrechterhaltenen (gegenüber der Klageschrift geringfügig reduzierten) Umfang begründet.

1. Der Unterlassungsanspruch folgt aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Soweit in Ziffer 1 der Urteilsformel anstelle des im Klageantrag enthaltenen Begriffs „umlaufendes Menü" der Begriff „rotierendes Menü" verwendet wird, liegt hierin keine Abweichung vom Klagebegehren. Die andere Fassung im Tenor berücksichtigt lediglich eine etwaige einengende Vorbelegung des Begriffs „umlaufend" dadurch, dass die Beklagtenseite unter umlaufend die Möglichkeit einer 360°-Drehung versteht, die der Patentanspruch nach Auffassung der Kammer gerade nicht voraussetzt.

2. Die Schadensersatzverpflichtung ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Beklagten ist einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Verletzung des Klagepatents zu machen. Da die Klägerin nicht in der Lage ist, den Schadensersatz zu berechnen, hat sie das für die Erhebung der Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse.

3. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch hat seine Grundlage in § 140b PatG, §§ 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufanspruch ergibt sich aus § 140a Abs. 1 Satz 1 PatG bzw. § 140a Abs. 3 Satz 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ.

a) Nachdem der geltend gemachte Rückrufanspruch sich nach der Teilklagerücknahme nur noch auf gewerbliche Abnehmer bezieht, waren Endabnehmer nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Urteil vom 8. April 2015 - 6 U 92/13, S. 29, unveröffentlicht) nicht von den Adressaten auszunehmen.

b) Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernung sowie Vernichtung der angegriffenen Ausführungsformen sind nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen.

aa) Solche Ansprüche sind nach § 140a Abs. 4 PatG dann ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist, wobei auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. Unverhältnismäßigkeit liegt vor, wenn - was vom Schuldner darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen ist - der rechtswidrige Zustand des Erzeugnisses oder der Geräte und Materialien auf andere Weise als durch die vollständige Vernichtung beseitigt werden kann oder wenn - trotz Fehlens einer Beseitigungsalternative - die Verhältnismäßigkeit sonst nicht gewahrt ist (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., Kap. D Rn. 540, 544 mwN).

bb) Mit ihrer pauschalen Berufung auf eine Unverhältnismäßigkeit hat die Beklagte das Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht dargetan. Es ist auch sonst nicht ersichtlich, in welcher Weise und mit welchem Inhalt etwa ein Update der immerhin zum Betriebssystem - also einem für jede Funktionsfähigkeit des Geräts wesentlichen Softwarebestandteil (zu bloßer Anwendungssoftware siehe hingegen LG Mannheim, InstGE 12, 136 [juris Rn. 327]) - der angegriffenen Geräte gehörenden Funktion „K" konkret durch die Beklagte als Schuldnerin der Verletzungsansprüche praktisch umgesetzt werden sollte. Denn die Programmierung dieser Funktion des Betriebssystems L dürfte nicht von der Beklagten herrühren, sondern von der Streithelferin. Das Bestehen einer - ohne weitere Darlegungen lediglich abstrakten - Möglichkeit von Softwareupdates, die die Patentverletzung

beseitigen könnten, vermag nicht die Annahme zu begründen, es lägen mildere, aber unter Berücksichtigung des Interesses der Klägerin an der Durchsetzung des Klagepatents hinreichend effiziente Alternativen zur Rückruf- und Vernichtungsverurteilung vor. Im Übrigen wäre zumindest ein Rückruf der Geräte auch für solche Softwareupdates erforderlich, weil nichts dazu vorgetragen ist, ob gewährleistet wäre, dass gegebenenfalls anzubietende Updates durch die gewerblichen Abnehmer der angegriffenen Mobilgeräte selbst tatsächlich durchgeführt würden (siehe auch LG Mannheim, InstGE 12, 136 [juris Rn. 326]). Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte (oder gar auf deren Anweisung hin die Abnehmer) anstelle des auf den Geräten installierten Betriebssystems ein anderes Betriebssystem installieren könnten und dass damit der patentverletzende Zustand beseitigt wäre. Ob eine - von Beklagtenseite schon gar nicht angesprochene - ersatzlose Deinstallation des Betriebssystems L die Beklagte wirtschaftlich in nennenswertem Maß geringer beeinträchtigen würde als eine Vernichtung der Geräte, kann die Kammer im Übrigen mangels Vortrags ebenfalls nicht feststellen, zumal die gewerbliche Verkehrsfähigkeit eines Mobiltelefons ohne Betriebssystem fraglich ist. Dass dem Rückruf schützenswerte Interessen der gewerblichen Abnehmer entgegenstehen, ist nicht erkennbar. Schließlich ist auch nicht ersichtlich, dass trotz Fehlen hinreichender Alternativen Vernichtung oder Rückruf und Entfernung von vorneherein außer Verhältnis zu dem Interesse der Klägerin an der Durchsetzung ihrer Rechte stünden.

IV.

Die Kammer setzt den Rechtsstreit nicht bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsklagen aus. Diese sind zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer übt aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von der Beklagtenseite glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende, mithin überwiegende Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 - Kurznachrichten; Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 107).

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen. Von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, ist die Kammer nicht überzeugt.

a) Dies gilt zunächst mit Blick auf die gerügte Neuheit des Anspruchs 1 des Klagepatents gegenüber dem EP 0 626 635 A2 (im Folgenden D 1).

aa) Die Kammer kann nicht annehmen, dass die Entgegenhaltung das Merkmal 1.2.4 offenbart.

Zwar weist das in der D 1 offenbarte Menü einen nicht-sichtbaren Bereich auf, in dem ohne Formatänderung im sichtbaren Bereich weitere Optionen hinzugefügt werden könnten. Die vom Merkmal 1.2.4 des Klagepatents geforderte Eignung ergibt sich bei dem Menü der D 1 indes nicht schon daraus, dass dieses sich zumindest dahin ausbilden ließe, dass beliebig viele Optionen hinzugefügt werden könnten, ohne dessen Format zu ändern. Vielmehr fordert der Wortlaut des Patentanspruchs 1, dass die beanspruchte Vorrichtung vorgesehen ist, dafür zu sorgen, dass Optionen tatsächlich (etwa durch Updates oder den Benutzer) hinzugefügt werden können, ohne dass das Format sich ändert. Eine bloße Eröffnung der abstrakten Möglichkeit einer solchen Menüausgestaltung genügt nicht. Sie ergibt sich bereits aus der Verwirklichung der Merkmale 1.2.1 bis 1.2.3. Dem

Merkmal 1.2.4 kommt hingegen ein weitergehender Gehalt bei der Bestimmung des Schutzbereichs zu, wonach eine erfindungsgemäße Vorrichtung die durch die Merkmale 1.2.1 bis 1.2.3 eröffneten Spielräume tatsächlich können nutzen muss, also („wodurch") ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl Optionen zu dem Menü hinzugefügt werden kann.

Dass eine solche Eignung des Menüs der D 1 als Teil einer technischen Lehre der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist, kann die Kammer nicht erkennen. Die Beklagtenseite hat insbesondere keine Beschreibungsstelle aufgezeigt, in der stünde, dass beliebig viele Optionen ohne Formatänderung hinzugefügt werden könnten. Insoweit hilft auch nicht der Verweis darauf weiter, dass die Darstellungen in den Figuren 13 und 14 lediglich konzeptionell seien und so nicht programmtechnisch realisiert seien, so dass ohne weiteres beliebig viele Optionen ohne Änderung des Formats des angezeigten Teils hinzugefügt werden könnten. Dass dies für den Fachmann klar sei, vermag die Kammer nämlich ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen - was dem Wesen der Aussetzungsprüfung als Prognoseentscheidung widerspräche - nicht mit der notwendigen Sicherheit festzustellen. Immerhin ist in den genannten Figuren der angezeigte Teil des Menübandes in einem bestimmten Radius gekrümmt, so dass man auch die Vorstellung entwickeln könnte, dass bei Hinzufügen weiterer Optionen sich dieser Radius verändert. Ob der Fachmann der Figur 12, die kein gekrümmtes Menüband zeigt, entnimmt, dass bei Hinzufügen weiterer Optionen keine Formatänderung bei einem „rotating menu" stattfindet, vermag die Kammer ohne sachverständige Hilfe ebenfalls nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren.

Dabei dürfte zudem klärungsbedürftig sein, ob der Fachmann der Anzeige eines Bandes überhaupt ein „rotating menu" im Sinn von Merkmal 1.2.1 entnimmt. Denn es spricht einiges dafür, dass die D 1 lediglich ein Menü offenbart, das sich den Betrachter wie aus deren Figur 12 ersichtlich darstellt, also nicht den Eindruck einer Drehbewegung, sondern eines linear verlaufenden Bandes erweckt und damit kein „rotating menu" im Sinn des Klagepatents darstellt. Soweit die Figur 13 einen Menüring zeigt (ebenso Figur 14), soll es sich nämlich nur um ein konzeptionelles Diagramm (offenbar betreffend die gedankliche Orientierung bei der Programmierung) des in Figur 12 offenbarten Menüs handeln (Beschreibung der D 1,

Sp. 20, insbes. Z. 43). Es scheint daher zweifelhaft, ob die D 1 (auch) ein Menü offenbart, das dem Betrachter gerade als rotierender Ring aus der Perspektive wie in Figuren 13 und 14 dargestellt werden soll.

bb) Die Kammer vermag dem Merkmal 1.2.4 auch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Technizität absprechen.

(1) Eine Technizität kann insbesondere bei informationsbezogenen Merkmalen, die etwa eine bestimmte Darstellungsweise zum Inhalt haben, fraglich sein. Eine Technizität und damit eine Berücksichtigungsfähigkeit des fraglichen Merkmals bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit liegt bei Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, oder Anweisungen, die dahingehen, eine Datenverarbeitungsanlage in bestimmter Weise zu programmieren, nicht vor. Anweisungen, die Informationen betreffen, die nach der erfindungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, können die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. Insoweit ist zu prüfen, ob das fragliche Merkmal sich zugleich als Ausführungsform eines - im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen - technischen Lösungsmittels darstellt (vgl. BGH, GRUR 2015, 1184 Rn. 18 - Entsperrbild).

(2) Unter Anlegung dieser Maßstäbe kann die Kammer die Technizität und damit die Berücksichtigungsfähigkeit des Merkmals 1.2.4 nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verneinen.

Zunächst ist festzuhalten, dass Merkmal 1.2.4 insoweit keine bloße Wirkung beschreibt, sondern vielmehr fordert, dass der Controller eingerichtet sein muss, um ein Hinzufügen einer beliebigen Anzahl weiterer Optionen zu dem Menü ohne Formatänderung zu ermöglichen. Hierdurch sind bestimmte Eigenschaften bzw. Fähigkeiten des Controllers angesprochen, die dieser haben muss, um patentgemäß zu sein. Er muss insbesondere dazu in der Lage sein, das Format - auch bei Drehungen - beizubehalten und nicht zu ändern.

Es sprechen auch gute Gründe dafür, dass die Merkmalsgruppe 1.2.1 bis 1.2.4 die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand hat. Die Klägerin weist nicht ohne Berechtigung darauf hin, dass es ein technisches Problem ist, dem Benutzer die effiziente Steuerung einer Vielzahl von Bedienungselementen trotz begrenzter Darstellungskapazität des Bildschirms zu ermöglichen. Es erscheint auch gut vertretbar, dass die hierfür vorgeschlagenen Mittel, nämlich ein rotierendes Menü zu verwenden, das Menü unzentriert darzustellen, so dass wenigstens eine Option aus dem Bildschirm wegdrehbar ist, und hierdurch zu ermöglichen, dass eine beliebige Anzahl von Optionen dem Menü ohne Formatänderung hinzugefügt werden können, technische Lösungsmittel sind. So könnte die Verschiebung einer Achse, um damit einen bestimmten Effekt zu erzielen, nämlich die Wegdrehbarkeit mindestens einer Option aus dem Bildschirm heraus, durchaus ein technisches Lösungsmittel sein, da es nicht allein um eine bessere Darstellung, sondern um die Lösung eines technischen Kapazitätsproblems geht. Auch die unterlassene Formatänderung trotz Kapazitätsproblemen, die hierdurch erst ermöglicht wird, könnte vor diesem Hintergrund technisch sein, zumal das Hinzufügen beliebig vieler Optionen, das der Controller leisten können muss, ohne Formatänderung gerade die Effizienz der Steuerung des Menüs für den Benutzer erhöht. Es spricht auch viel dafür, dass die Merkmale 1.2.2 bis 1.2.4 mit ihrem aufeinander aufbauenden Wirkzusammenhängen Aspekte der technischen Lösung des technischen Problems darstellen, die nicht bereits in anderen Merkmalen des Patentanspruchs zum Ausdruck kommen. Jedenfalls vermag die Kammer nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, dass dem Merkmal 1.2.4 eine Technizität abgesprochen werden wird. Es kann daher offenbleiben, ob nicht-technische Merkmale auch bei der Neuheitsprüfung nicht zu berücksichtigen sind.

b) Die Kammer erwartet auch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, dass die Lehre des Klagepatents sich als nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung EP 0 767 418 A1 (im Folgenden D 2) erweisen wird.

aa) Unabhängig von der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, ob das Klagepatent seine Priorität vom 20. Dezember 1996 zu Recht in Anspruch nimmt, handelt es sich bei der am 2. Oktober 1996 angemeldeten und nach dem

Prioritätstag veröffentlichten D 2 allerdings jedenfalls um nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigenden Stand der Technik.

bb) Die Kammer kann sich indes auch bei dieser Entgegenhaltung keine hinreichende Überzeugung hinsichtlich der Offenbarung des Merkmals 1.2.4 bilden.

Auch bei ihr mag zwar das gezeigte Menü dazu geeignet sein, so ausgebildet zu werden, dass eine beliebige Anzahl von weiteren Optionen ohne Formatänderung hinzugefügt werden kann, da keine Vorgaben für die Ausgestaltung des Menüs außerhalb des sichtbaren Bereichs gemacht werden und das gezeigte Karussell lediglich ein gedankliches Konzept ist, das so nicht programmtechnisch umgesetzt werden muss. Allerdings gilt wie bei Entgegenhaltung D 1, dass als Teil einer technischen Lehre unmittelbar und eindeutig offenbart sein müsste, dass der Controller auch tatsächlich so eingerichtet ist, dass ohne Änderung des Formats eine beliebige Anzahl Optionen zu dem Menü hinzugefügt werden kann (s.o.). Eine Offenbarung dieses Inhalts, der die Kammer aufgrund eigener Sachkunde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine neuheitsschädliche Offenbarung dieses Merkmals entnehmen könnte, hat die Beklagtenseite nicht aufgezeigt.

Insbesondere vermag die Kammer der Beschreibungsstelle in Spalte 6 Zeilen 52 bis 58 der D 2 keine solche Offenbarung mit hinreichender Gewissheit entnehmen. Dort ist zwar ausgeführt, dass - weil die Menüsymbole zylindrisch angezeigt würden - dann, wenn die Anzahl der darzustellenden Menüsymbole erhöht werde, eine größere Anzahl von Menüsymbolen in einfacher Art und Weise zur Verfügung gestellt werden könne, ohne dass der Nutzer die Erhöhung der Menüsymbole bemerke. Allerdings heißt es im gleichen Satz, dass dies durch Vergrößerung des Radius des Zylinders geschehe. Auch wenn der Benutzer von einem Anstieg der Menüoptionen nichts bemerken soll, bestehen Zweifel, ob dies auch bedeuten soll, dass eine Formatänderung nicht stattfindet. Eine Vergrößerung des Radius des (gedachten) Zylinders stellt eine Formatänderung dar. Die Beklagtenseite hat keine Stelle in der Entgegenhaltung aufgezeigt, in der hinreichend klar zum Ausdruck gebracht wird, dass von der Radiusänderung der Krümmungsradius des angezeigten Teils des Menüs ausgenommen ist. Insbesondere lässt sich der Aussage, dass der Nutzer die Erhöhung der

Menüsymbole nicht bemerke, nicht zwangsläufig entnehmen, dass sich der Krümmungsradius des gezeigten Menüausschnittes nicht ändert. Die Beschreibungsstelle nimmt lediglich Bezug auf die Erhöhung der Menüsymbole, die der Benutzer nicht bemerken soll, nicht jedoch auf die Vergrößerung des Radius. Dass der Benutzer eine Änderung des Radius bemerkt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch bemerkt, dass die Anzahl der Menüoptionen sich erhöht hat. Jedenfalls ist nicht hinreichend sicher ausgeschlossen, dass die Vergrößerung des Radius des Zylinders zu einer sichtbaren Veränderung des auf dem Bildschirm gezeigten Teils des Zylinderbogens führt. In diesem Fall wäre gerade eine Formatänderung im sichtbaren Bereich im Sinne des Klagepatents gegeben, was einer Offenbarung des Merkmals 1.2.4 entgegenstünde. Das Merkmal Formatänderung kann auch nicht einengend dahingehend ausgelegt werden, dass es nur solche Formatänderung erfassen soll, die das Menü komplizierter machen, und (kleinere) Änderungen des Krümmungsradius im angezeigten Menüausschnitt nicht erfasst. Eine solche Einschränkung enthält der Wortlaut des Patentanspruchs nicht. Sie kann insbesondere nicht der Beschreibungsstelle [0011] der Klagepatentschrift entnommen werden, zumal sich diese nur auf ein Ausführungsbeispiel bezieht.

Soweit die Beklagtenseite auf den Fachmann verweist, vermag die Kammer aus den bereits dargelegten Gründen hierauf keine Aussetzungsentscheidung stützen.

c) Auch auf der Grundlage der Entgegenhaltung D 3c (FSN-System) kann die Kammer nicht die Prognose treffen, dass der Anspruchs 1 des Klagepatent mangels Neuheit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird.

Dahinstehen kann, ob im FSN-Menü vorgesehen ist, dass eine beliebige Anzahl weiterer Menü-Optionen ohne Formatänderungen hinzugefügt werden kann. Beim FSN-Menü ist jedenfalls keine Wegdrehbarkeit vom Bildschirm im Sinne einer Wegdrehbarkeit über den Bildschirmrand gegeben, wie sie die Merkmale 1.2.2 und 1.2.3 des Klagepatents lehren. Denn beim Drehen werden die Optionen des FSN-Menüs nicht über den Bildschirmrand hinaus weggedreht. Eine Vorwegnahme kann sich dann nicht daraus ergeben, dass beim FSN-Menü einzelne Optionen aus perspektivischen Gründen nicht (inhaltlich) wahrnehmbar dargestellt werden, nämlich

wenn sie in die äußersten linken und rechten Positionen des Karussells gebracht werden, sich also zwar innerhalb des auf dem Bildschirm dargestellten Raums befinden, aber nicht sichtbar sind. Denn dies beruht nicht auf einer dezentralen Darstellung des Menüs, die aber nach der Lehre des Klagepatents das Mittel darstellen muss, um die Wegdrehbarkeit herbeizuführen. Die Einschränkungen bei der Wahrnehmbarkeit einzelner Menüpunkte sind beim FSN-Menü vielmehr unabhängig von einer zentrierten oder aus der Mitte versetzten Anordnung des Menüs.

d) Auch mit Blick auf die Entgegenhaltung Lifestreams-Benutzeroberfläche gemäß dem Artikel von Freeman und Fertig (Anlage D 4 bzw. NK 4 zu den Nichtigkeitsklagen, im Folgenden D 4) kann die Kammer nicht hinreichend sicher prognostizieren, dass diese die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnimmt. Dabei kann die Kammer zu Gunsten der Beklagten unterstellen, dass es sich bei dieser Veröffentlichung um Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents handelt.

aa) Es bestehen insbesondere erhebliche Zweifel, ob der Fachmann dem ein „rotating menu" im Sinn der Merkmale 1.2.1 und 1.2.3 entnehmen kann. Ob die leichte Krümmung des angezeigten Teils des Dokumentenstroms als Teil einer unmittelbar und eindeutig offenbarten technischen Lehre anzusehen ist und bereits die leichte Krümmung Raum für die Annahme eines „rotating menu" gibt, kann dabei offenbleiben. Zwar mag die Veröffentlichung offenbaren, dass die Lifestream-Benutzeroberfläche ermöglicht, durch den darin dargestellten Dokumentenstrom zu scrollen, wodurch der Teil der sichtbaren Dokumente geändert wird. Der Klägervertreter hat indessen in der mündlichen Verhandlung auf die nicht fernliegende Möglichkeit hingewiesen, dass der Benutzer (nur) mittels des in der Figur 1 der D 4 links unten gezeigten Scrollbalkens durch den Dokumentenstrom navigiert und dessen Verschiebung nicht zu einer gleichzeitigen stufenlosen Drehung des Dokumentenstroms, sondern lediglich zu einer neuen Befüllung („update") der einzelnen Karteikarten/Fenster im Dokumentenstrom nach Beendigung der Verschiebung des Scrollbalkens führt (so beschrieben in der späteren Veröffentlichung desselben Erstautors NK 4b, S. 66). Die Kammer kann daher nicht erkennen, dass die Lifestreams-Benutzeroberfläche eine Rotation, insbesondere die

Möglichkeit eines Wegdrehens im Sinn des Klagepatents vorsieht und die D 4 dies offenbart. Vielmehr werden dort möglicherweise lediglich fest angeordnete Fenster je nach der vom Benutzer mittels der Scrollbalkens vorgenommenen Auswahl mit Dokumenten („Optionen") gefüllt. Ein solches Springen der Optionen an eine andere Stelle ist aber keine Rotation im Sinn des Klagepatents. Diese setzt vielmehr eine Drehbewegung voraus, weil es sonst nicht zu einem „Wegdrehen" nach Merkmal 1.2.3 kommen kann.

bb) Im Übrigen offenbart die D 4 nicht die Verwirklichung des Merkmals 1.2.4. Beim Hinzufügen neuer Dokumente mögen die bereits vorhandenen um eins nach hinten versetzt werden. Der D 4 ist aber nicht zu entnehmen, dass dies ohne Formatänderung des Menüs geschieht, namentlich dass gleichzeitig ein Dokument nach hinten aus dem Bildschirm verschwindet, wenn ein neues hinzugefügt wird, also die Anzahl der im sichtbaren Menü-Teil gezeigten Dokumente nicht erhöht und die Krümmung des Dokumentenstroms nicht verändert wird.

e) Der Offenbarungsgehalt der NK 4a geht insoweit nicht entscheidend weiter, so dass die Kammer auch nicht aufgrund dieser Entgegenhaltung von einer Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents ausgehen kann.

aa) Es fehlt zunächst an einer Offenbarung des Merkmals 1.2.4. Dahinstehen kann dabei, ob bei dem - nach dem Vortrag der Nichtigkeitsklage - zeitlich der D 4 nachfolgenden wissenschaftlichen Beitrag desselben Erstautors gemäß der NK 4a der Offenbarungsgehalt der D 4 mit einzubeziehen ist, und ob sich aus einer Gegenüberstellung der Figur 1 der D 4 und der Figur 1 der NK 4a (unter Berücksichtigung der darin über dem Scrollbalken jeweils angegebenen Gesamtanzahl von Dokumenten) ergeben könnte, dass die Darstellung des sichtbaren Bereichs des Dokumentenstroms unabhängig von der aktuellen Gesamtzahl von Dokumenten gleich bleibt (Anzeige eines 45 Dokumente umfassenden Ausschnitts). Denn der letztgenannte Umstand ist nicht durch eine gewissermaßen kombinierte Entgegenhaltung bestehend aus dem Offenbarungsgehalt der D 4 und der NK 4 als technische Lehre unmittelbar offenbart, zumal auf diesen Aspekt in den Aufsätzen nicht erkennbar eingegangen wird. Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung liegt nicht darin, dass die Beibehaltung des

Formats sich durch ein jeweiliges Abzählen der in den Figuren der beiden Aufsätze sichtbaren Dokumente erkennen ließe.

bb) Selbst wenn man dies aber anders sehen wollte (etwa mit Blick auf die jüngsten Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom 18. Oktober 2016, wonach die NK4a offenbare, dass ältere Dokumente sowohl bei der Verschiebung der Auswahl in die „Zukunft" als auch beim Neueingang von Dokumenten aus der Anzeige verschwinden), wäre der NK 4a aus den bereits zur D 4 ausgeführten Gründen (auch in Verbindung mit der D 4) nicht zu entnehmen, dass überhaupt ein „rotating menu" vorliegt, dessen Menüpunkte gedreht, insbesondere weggedreht werden können (Merkmal 1.2.1 und 1.2.3).

f) Auch eine Vernichtung des Klagepatents wegen angeblicher Vorwegnahme seiner Lehre durch die Dissertation NK 4b des genannten Autors kann die Kammer nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit prognostizieren.

aa) Dem steht schon entgegen, dass die Nichtigkeitsklage von einer Veröffentlichung der Entgegenhaltung erst im Mai 1997 ausgeht, die nach dem Prioritätstag des am 10. November 1997 angemeldeten Klagepatents liegt. Die Kammer kann nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren eine wirksame Inanspruchnahme des Prioritätsdatums der US 772080 vom 20. Dezember 1996 verneinen wird.

Eine berechtigte Inanspruchnahme setzt allerdings nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ voraus, dass die Klägerin als Anmelderin des Klagepatents zumindest „Rechtsnachfolger" des Anmelders der Prioritätsschrift war. Eine Rechtsnachfolge in diesem Sinn kann insbesondere darin liegen, dass - wie die Klägerin behauptet - die gesamte Voranmeldung übergegangen ist. Die Rechtsübertragung muss rechtzeitig - d. h. vor Einreichung der Nachanmeldung - und wirksam geschehen sein (BGH, GRUR 2013, 712 Rn. 11 - Fahrzeugscheibe).

Die Rechtsnachfolge ist vorliegend zwar bestritten. Die Klägerin hat sich jedoch zum Nachweis der Übertragung der Prioritätsanmeldung von der M an die Klägerin auf den von der Streithelferin als Anlage SH 15 vorgelegten Auszug aus einem „General Services Agreement", einer Vereinbarung zwischen der Klägerin und

der N und deren verbundenen Unternehmen berufen. Ob insbesondere auf der Grundlage dieses Dokuments - unter Berücksichtigung der von der Streithelferin aufgeworfenen Fragen nach der Beteiligung der M am Vertrag und der Erfassung der nach dem Vertragsdatum erfolgten Prioritätsanmeldung - eine Übertragung der Prioritätsanmeldung auf die Klägerin zu entnehmen ist, obliegt der freien Beweiswürdigung im Nichtigkeitsverfahren, deren Ausgang die Kammer - auch bei einer Beweislast der Nichtigkeitsbeklagten - nicht prognostizieren kann. Eine wirksame (antizipierte) Übertragung der Prioritätsanmeldung scheint jedenfalls nicht ausgeschlossen, auch weil die Vereinbarung sich allgemein auf alle Rechte aus Erfindungen der Beschäftigten (nicht etwa bloß bereits erfolgte Patentanmeldungen) der übertragenden Vertragsparteien bezieht.

bb) Im Übrigen kann die Kammer nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der NK 4b die klagepatentgemäße Lehre zu entnehmen ist. Zwar mag sich aus einer Gegenüberstellung ihrer Figuren 4.1 und 4.3 (NK 4b, S. 65, 68) ergeben, dass die Anzahl sichtbarer Dokumente und damit das Format des sichtbaren Teils des „Menüs" unabhängig vom Umfang des gesamten Datensatzes (Fig. 4.1: 17.338 Dokumente; Fig. 4.3: 102 Dokumente) identisch bleiben. Wie bereits bei der D 4 und der NK 4a fehlt es aber zumindest an der Offenbarung eines „rotating menu", bei dem Menüoptionen weggedreht werden können (Merkmale 1.2.1 und 1.2.3).

g) Bei der mit Nichtigkeitsklage von C eingeführten Entgegenhaltung WO 96/25747 A1 (D 5) kann die Kammer ebenfalls nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents ausgehen.

aa) Wie bei der D 1 ist - mit Blick auf Merkmal 1.2.4 des Klagepatents - nicht erkennbar, ob das bei der D 5 in Figur 6 gezeigte Menü, auf das die Nichtigkeitsklage sich bezieht, tatsächlich dazu eingerichtet ist, beim Hinzufügen weiterer Optionen (Informationsflächen) das Darstellungsformat (Abstand der Informationsflächen und Radius der angeblich karussellartigen Anordnung) beizubehalten.

bb) Im Übrigen ist nicht aufgezeigt, dass die D 5 offenbart, dass bei dem darin gezeigten Menü einzelne Optionen (Informationsflächen) gerade wegen eines Versatzes des Menüs aus der Bildschirmmitte weggedreht werden können

(Merkmale 1.2.2 und 1.2.3). Auf der linken Seite der Figur 6 der D 5, also im vom Betrachter entfernteren Teil des Menürades, findet ein solches Wegdrehen nicht statt, weil die Informationsflächen dort hinter der Nabe des gezeigten Rades verschwinden. Auf der rechten Seite ist ein erfindungsgemäßes Wegdrehen ebenfalls nicht erkennbar, weil die Nichtigkeitsklage lediglich geltend macht, dass sich Informationsflächen wegdrehen, wenn der Benutzer das Menü zu sich hindreht. Soweit aber die weggedrehte Informationsfläche nur deshalb unsichtbar wird, weil sie sich mit einer Rotation des Menüs vor die Ebene des Bildschirms bewegt (und nicht etwa deshalb, weil sie über den rechten Bildschirmrand hinausbewegt würde), fehlt es entgegen der Lehre des Klagepatents an dem funktionalen Zusammenhang mit einem Versatz des Menüs aus der Mitte und der Ermöglichung des Wegdrehens.

h) Die Kammer kann nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erkennen, dass das Klagepatent wegen mangelnder Neuheit gegenüber den „Demo One"-Menüs der Playstation-Spielkonsole (siehe die Screenshots gemäß Anlage AR 7 zur Akte 2 O 229/15) vernichtet werden wird.

aa) Dies gilt zunächst schon deshalb, weil die Klägerin bestritten hat, dass die Demo-CD mit dem von der Nichtigkeitsklage behaupteten Inhalt vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents veröffentlicht worden ist. Ob der Nachweis dieser Tatsache im Nichtigkeitsverfahren anhand der hierfür eingereichten angeblichen Belege (Anlagen AR 4 ff, AR 11 und AR 18 zur Akte 2 O 229/15) gelingen wird, kann die Kammer nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit prognostizieren.

bb) Unabhängig davon lässt diese Entgegenhaltung mit den Menüs PREVIEW und GAMES eine Offenbarung der Lehre des Klagepatents nicht erkennen.

(1) Dies gilt insbesondere, soweit Merkmal 1.2.4 verlangt, dass Menüoptionen (ohne Formatänderung) hinzugefügt werden können. Die beiden entgegengehaltenen Menüs weisen zwar bei gleichem Format eine unterschiedliche Anzahl von Einträgen (Optionen) auf, nämlich einerseits sieben und andererseits fünf Optionen. Es ist aber nicht ersichtlich, dass sie dazu eingerichtet sind, dass jeweils innerhalb eines Menüs (nachträglich) Menüoptionen hinzugefügt werden können (noch dazu ohne Formatänderung). Dies verlangt der Patentanspruch aber, indem er einen Controller lehrt, der dazu vorgesehen ist, die in den Merkmalen 1.2.1 bis 1.2.4

im Einzelnen beschriebenen Wirkungen zu erzielen. Es genügt dafür nicht, dass die Menüs der „Demo One"-CD durch Umprogrammieren des Controllers um Menüoptionen ergänzt oder verkürzt werden könnten (wie es bei der Entwicklung der Menüs PREVIEW oder GAMES geschehen sein mag). Ob insoweit eine Hinzufügbarkeit durch Software-Updates patentgemäß sein könnte, kann aber dahinstehen. Ein Hinzufügen von Menüoptionen durch Updates dürfte bei den vermutlich als ROM-Datenträger ausgestalteten Demo-CDs nämlich in tatsächlicher Sicht ausgeschlossen sein. Gegenteiliges macht die Nichtigkeitsklage im Übrigen ohnehin nicht gelten.

(2) Zudem ist das Merkmal 1.2.3 nicht offenbart.

Eine patentgemäße Wegdrehbarkeit besteht auf der linken Seite des Menüs nicht, weil die Menüeinträge bei ihrer Bewegung nach (perspektivisch) links hinten lediglich immer kleiner werden und letztlich innerhalb der Bildschirmfläche auf eine Weise verschwinden, die den Eindruck erweckt, sie seien wegen der immer größeren Entfernung nicht mehr zu sehen. Ein durch einen Versatz des Menüs aus der Mitte beeinflusstes Wegdrehen liegt darin nicht. Die kleiner werdenden Menüpunkte würden auf dieselbe Weise verschwinden, wenn die Menübahn, deren Eindruck die „Demo One"-Menüs beim Betrachter erwecken, vollständig im durch den Bildschirm gebildeten Sichtkorridor angeordnet wäre. Lediglich der vordere/obere Teil der dem Betrachter in der Entgegenhaltung vorgegaukelten Menübahn führt nach oben aus dem Bildschirm hinaus.

Aber auch eine Wegdrehbarkeit über den Bildschirmrand nach oben (also im rechten, dem Betrachter näheren Bereich des Menüs) zeigt die Nichtigkeitsklage nicht auf. Vielmehr ergibt sich das Gegenteil aus den vorgelegten Videos. Das auf der Anlage AR 6 zeigt nämlich bei 8:28 min eine Rotationsbewegung des Menüs, bei welcher der Menüpunkt „TEKKEN" von der zweiten Position von oben in die oberste Position gleitet und die in Drehrichtung dahinter befindlichen Optionen entsprechend nachrücken. Der zuvor an oberster Stelle befindliche Eintrag „STARBLADE" wird aber nicht aus dem sichtbaren Bereich gedreht, sondern verblasst unbeweglich an derselben Stelle, wo er vom hochrotierten Menüpunkt „TEKKEN" überdeckt wird. Eine (insbesondere durch einen Versatz des Menüs beeinflusste) Wegdrehbarkeit

von Menüoptionen sieht die aus Playstation und Demo-CD folglich auch nicht an dieser Stelle vor.

i) Eine Aussetzung ist auch nicht angezeigt, soweit der Neuheit des Klagepatents das Menü der Playstation-Demo-CD „autumn/Christmas releases 1996" (siehe die Screenshots gemäß Anlage AR 9 zur Akte 2 O 229/15) entgegengehalten wird. Die dazu nachfolgenden Erwägungen gelten entsprechend für die zuletzt mit Schriftsatz vom 5. September 2016 zum Verfahren 2 O 229/15 ergänzten Ausführungen zu gleichartigen Menüs mit unterschiedlicher Anzahl von Menüpunkten auf anderen Demo-CDs.

aa) Auch insoweit kann schon nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden, ob die Veröffentlichung der Demo-CDs mit dem behaupteten Inhalt vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren mit den dazu vorgelegten Belegen (Anlagen AR 4 ff und AR 11 zur Akte 2 O 229/15) bewiesen werden wird. Diese Tatsache ist aber von der Klägerin bestritten worden. Bei vernünftiger Würdigung sind die Ausführungen in deren Schriftsatz vom 4. Oktober 2016 nicht anders zu verstehen. Sie beziehen sich nicht nur auf die u.a. vorgelegten Videos und deren Veröffentlichung. Denn die Klägerin hat diese unter die Überschrift „Demo-CDs nicht neuheitsschädlich" gestellt und mit Nichtwissen insbesondere die Identität der vorgelegten CDs mit einer seinerzeit in einer Zeitrschrift veröffentlichten CD bestritten. Selbst wenn die Klägerin in diesem Punkt den Vortrag der Nichtigkeitsklage der Fa. B missverstanden haben sollte, soweit vielmehr eine Beifügung der Demo-CDs in der Verpackung ausgelieferter Playstations geltend gemacht wird, kann daraus nicht auf ein fehlendes Bestreiten der Vorveröffentlichung der Demo-CDs als Entgegenhaltungen geschlossen werden. Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind dann nicht als zugestanden anzusehen, wenn die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht (vgl. § 138 Abs. 3 ZPO). Zumindest letzteres ist hier aber der Fall, weil die Klägerin sich ersichtlich mit Nichtwissen dazu erklären will, dass die behauptete Veröffentlichung mit dem Inhalt der nun vorgelegten CDs übereinstimmt. Andernfalls ergäbe die bestreitende Einlassung betreffend eine (irrtümlich angesprochene) Beifügung zu einem Magazin keinen Sinn. Ob der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren ein Bestreiten mit Nichtwissen wegen eigener Kenntnisse zu

diesem Sachverhalt versagt werden wird, kann die Kammer nicht beurteilen. Insoweit spricht gegen eine Aussetzung im Übrigen, dass die Klägerin bisher nur wenig Zeit hatte, sich mit diesen jüngst eingeführten Entgegenhaltungen zu befassen, insbesondere Erkundigungen zum Veröffentlichungszeitpunkt anzustellen. Anlass für einen weiteren Schriftsatznachlass zu Gunsten der Beklagten besteht insoweit nicht, zumal die Klageanträge entscheidungsreif sind und die Kammer es nicht für angezeigt hält, deren Entscheidung zu verzögern, um der Beklagten Gelegenheit zu geben, ihren Aussetzungsantrag weiter zu begründen. Eines Hinweises der Kammer dazu, ob die Vorveröffentlichung hinreichend wahrscheinlich ist, bedurfte es nicht, insbesondere nicht in der mündlichen Verhandlung, zu deren Zeitpunkt die Klägerin zu diesem Element des Rechtsbestandsangriffs noch gar nicht abschließend Stellung nehmen konnte. Ohnehin hat die Kammer keine Hinweise zu einer eventuellen Beweisfälligkeit im Nichtigkeitsverfahren zu erteilen, da sie eine dort eventuelle erforderliche Beweisaufnahme nicht durchzuführen, sondern lediglich Überlegungen zum voraussichtlichen Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens anzustellen hat.

bb) Darauf kommt es indes letztlich nicht entscheidend an, weil die Entgegenhaltung „autumn/Christmas releases 1996" ohnehin nicht die Lehre des Klagepatents offenbart.

(1) Wie bei den Menüs der „Demo One"-CD lässt die Entgegenhaltung nicht erkennen, dass der Controller dafür eingerichtet ist, dass Menüpunkte überhaupt (und zudem ohne Formatänderung) hinzugefügt werden können (Merkmal 1.2.4).

(2) Darüber hinaus fehlt es an einer funktional mit einem Versatz des Menüs aus der Mitte in Verbindung stehenden Wegdrehbarkeit (Merkmale 1.2.2 und 1.2.3).

Die Menübahn der Entgegenhaltung mag sich als rotierender Ring darstellen, der in der im Wesentlichen horizontal und in derselben Ebene liegt, in der auch die Blickrichtung des Betrachters liegt. Denn der in der Mitte dargestellte Menüpunkt erscheint am größten (also am nächsten), während die jeweils zwei weiteren Menüoptionen symmetrisch links und rechts davon umso kleiner sind, je weiter sie vom mittleren Menüpunkt entfernt sind. Dabei scheint der Ring sich perspektivisch leicht oberhalb des Blickpunkts des Betrachters zu befinden, weil mit der Bewegung von Menüpunkten nach außen deren oberer Rand nach unten rückt, der untere Rand

aber auf einer Höhe bleibt. Dabei mag man wegen der Anordnung des Menürings im unteren Bildschirmdrittel davon ausgehen, dass das Menü im Einklang mit Merkmal 1.2.2 außerhalb der Mitte der Wiedergabeanordnung vorgesehen ist. Auch führt eine Drehung des Menürings dazu, dass der in Drehrichtung vorderste noch sichtbare Menüpunkt sich in einen nicht sichtbaren Bereich am Bildschirmrand bewegt. Es scheint aber schon fraglich, ob hier überhaupt eine Wegdrehbarkeit von der Wiedergabeanordnung („*rotatable off the display*") im Sinn des Merkmals 1.2.3 in Betracht kommt, wenn man berücksichtigt, dass die Menüpunkte schon vor Erreichen des Bildschirmrandes nicht wegen der begrenzten Displayfläche, sondern deshalb verschwinden, weil sie sich scheinbar hinter die das Menü umgebende silbrig glänzende Oberfläche bewegen.

Selbst wenn man dies aber als Wegdrehen von der Wiedergabeanordnung begreifen wollte, stünde diese Wegdrehbarkeit jedenfalls entgegen den Merkmalen 1.2.2 und 1.2.3 in keinem Zusammenhang mit dem Versatz des Menüs aus der Mitte. Die Nichtigkeitsklage geht offenbar von einer seitlichen Wegdrehbarkeit nach außen, also in horizontaler Richtung aus. Insoweit besteht kein Zusammenhang mit dem Versatz des Menüs in den unteren Bildschirmbereich. Die Positionierung des Menüs im Vergleich zu linkem und rechtem Bildschirmrand, die allein für eine seitliche Wegdrehbarkeit relevant sein könnte, ist hingegen zentriert. Es ist auch keine durch den Versatz des Menüs nach unten bedingte Wegdrehbarkeit nach (schräg) unten erkennbar, da die Unterkanten der fünf sichtbaren Menüpunkte alle gleich weit vom Bildschirmrand entfernt sind, eine Bewegung unter die Höhe der Bildschirmunterkante also auch in der gedachten Fortsetzung der Menübahn nicht erfolgt.

j) Ferner kann die Kammer nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich eine Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents aufgrund der Entgegenhaltung „Killer Instinct Gold" (Schriftsatz vom 5. September 2016 zu 2 O 229/16, dort S. 2 ff) ergeben wird.

Es handelt sich nach dem Vortrag der Nichtigkeitsklage um ein Videospiel für die Konsole Nintendo 64, das im Juli 1996 zunächst in Japan erschienen sein soll. Selbst wenn es zum Stand der Technik zählen sollte, kann die Kammer nicht

erkennen, dass sein Offenbarungsgehalt der Neuheit des Klagepatents entgegenstünde.

aa) Wie bei den zuletzt erörterten Playstation-Demos ist nicht aufgezeigt, dass die Nintendo 64-Konsole in Verbindung mit der Spiel-CD dazu eingerichtet ist, Menüoptionen (Spielfiguren) hinzuzufügen (zudem ohne Formatänderung), wie es Merkmal 1.2.4. verlangt.

bb) Ferner vermag die Kammer der Entgegenhaltung keine eindeutige Offenbarung der Merkmale 1.2.2 in Verbindung mit 1.2.3 zu entnehmen. Die Klägerin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass insbesondere der auf S. 16 ihres Schriftsatzes vom 4. Oktober 2016 gezeigte Screenshot es nahelegt, dass das Menükarussell sich nicht (gedacht) über den linken Bildschirmrand hinaus fortsetzt, weil der Menüpunkt auf seiner linken Seite dort in derselben Weise aus perspektivischen Gründen nur noch teilweise sichtbar erscheint wie der Menüpunkt auf der rechten Seite, während sich beide genannten Menüpunkte offenbar in der jeweils äußersten horizontalen Auslenkung der Menübahn befinden. Dann wird aber offenbar auch der Menüpunkt auf der linken Seite nicht weggedreht; vielmehr verschwindet er - genauso wie es Menüpunkte auf der rechten Seite tun - letztlich hinter dem Menükarussell, ohne den Bildschirmbereich verlassen zu haben. Hierin liegt keine durch den Versatz des Menüs aus der Mitte beeinflusste Wegdrehbarkeit. Dass entgegen der Deutung der Klägerin sich das Karussell der Entgegenhaltung tatsächlich doch (gerade noch) minimal aus dem Displaybereich hinausbewegt, kann die Kammer der Entgegenhaltung jedenfalls nicht eindeutig, insbesondere nicht als erkennbare technische Lehre entnehmen.

k) Schließlich kann die Kammer eine Vorwegnahme durch die mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2016 im Verfahren 2 O 229/15 und dort insbesondere mit den Anlagen AR 19 ff ergänzte Entgegenhaltung „Ridge Racer“ nicht erkennen. Die Kammer konnte sich anhand der dieses Menü zeigenden Videos der Anlage AR 19 einen Eindruck davon verschaffen, wie die Bewegung der Menüoptionen (Autos) in diesem Videospiel verläuft. Ein gekrümmter Bewegungsverlauf ist der Entgegenhaltung danach nicht zu entnehmen. Vielmehr erweckt die Bewegung der Menüoptionen den Eindruck, dass diese sich auf einer linearen Bahn bewegen, die

sich zu beiden Seiten geradlinig aus dem Bildschirm hinaus erstreckt. Damit fehlt es schon an der Offenbarung eines rotierenden Menüs nach Merkmal 1.2.1, aber u.a. auch an einer Wegdrehbarkeit nach Merkmal 1.2.3, die zudem gerade in einem Zusammenhang mit einer Anordnung des Menüs außerhalb der Mitte nach Merkmal 1.2.2 stünde.

l) Die Kammer kann dem Patentanspruch 1 auch das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit absprechen.

Auch wenn zum Beleg der fehlenden erfinderischen Tätigkeit neuer Stand der Technik präsentiert wird, der im Erteilungsverfahren noch nicht geprüft wurde, kann eine hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn sich auch für die Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen im Nichtigkeitsverfahren abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. Dies ist vorliegend der Fall.

Die Klägerin hat ausgeführt, dass die Übertragung der für lineare Menüs vorbekannten ausschnittsweisen Anzeige auf rotierende Menüanordnungen nicht nahegelegen habe, da der Fachmann keine Veranlassung hierfür gehabt habe. In der Tat erscheint es nicht von vorneherein unplausibel, im Falle einer Vielzahl von Menüoptionen den Umfang zu erhöhen oder die Optionssymbole zu verkleinern. Stößt der Fachmann hierbei an Grenzen, scheint nicht ausgeschlossen, dass er dann eher zu anderen Menüanordnungen wie etwa einem linearen Menü übergeht. Die Beklagtenseite hat nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit aufgezeigt, dass der Fachmann stattdessen veranlasst gewesen sein sollte, eine Hinzufügbarkeit von beliebig vielen Menüpunkten ohne Formatänderung gerade dadurch zu erreichen, dass er (wie die Merkmale 1.2.2 bis 1.2.4 des Klagepatents lehren) ein rotierendes Menü so außerhalb der Mitte des Bildschirms anordnet, dass der Eindruck einer geschlossenen Menübahn erweckt werden kann, weil Menüoptionen aufgrund des Versatzes aus dem Bildschirm weggedreht werden können.

Insoweit kann dem Aussetzungsbegehren insbesondere nicht zum Erfolg verhelfen, wenn ein Vergleich der Menüs PREVIEW und GAMES der „Demo-One"-CD und Figuren 4.1 und 4.3 der NK 4b erkennen lassen sollte, dass ein

Unsichtbarmachen eines Teils des Menüs durch seinen Versatz aus der Mitte des Bildschirms es allgemein ermöglicht, ein bestimmtes Darstellungsformat unabhängig von der Anzahl der insgesamt vorhandenen Optionen beizubehalten. Denn wie ausgeführt kann die Kammer schon nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit prognostizieren, dass die bestrittene Zugehörigkeit dieser Entgegenhaltungen zum Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren festgestellt werden wird. Soweit auch die Menüs vom Typ „autumn/Christmas releases 1996" und „Ridge Racer" unterschiedliche Anzahlen von Menüeinträgen bei gleichem Format aufweisen mögen, stellt dies die Erfindungshöhe des Klagepatents schon deshalb nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit in Frage, weil nicht ersichtlich ist, welchen Anlass der Fachmann gehabt haben sollte, darüber hinaus insbesondere die in diesen Entgegenhaltungen nicht einmal angedeutete Wirkung der Merkmale 1.2.2 und 1.2.3 des Klagepatents (Wegdrehbarkeit durch Versatz des Menüs aus der Mitte) hinzuzufügen. Aus den bereits zur NK 4a ausgeführten Gründen kann auch nicht angenommen werden, dass ein Vergleich der Entgegenhaltungen D 4 und NK 4a dem Fachmann Anlass zur Verwirklichung der Lehre des Klagepatents gegeben haben sollte, zumal deren Inhalt keinen Anlass zu einem analytischen Vergleich der Darstellungsformen in den dortigen jeweiligen Figuren, insbesondere einem Abzählen der jeweils sichtbaren Dokumente gegeben hat.

Soweit die Beklagtenseite auf fachmännisches Wissens abhebt, kann dem bei der Entscheidung über die Aussetzung nicht nachgegangen werden. Die Kammer hat wie bereits dargelegt lediglich eine Prognose über die Entscheidung der für die Prüfung des Rechtsbestands zuständigen Instanzen anzustellen und kann nicht selbst etwa unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen das Fachwissen des maßgeblichen Fachmannes ermitteln, wenn sie - wie vorliegend - diesen Kenntnisstand nicht oder nicht mit der für eine Aussetzung notwendigen Sicherheit vorgelegten Unterlagen entnehmen kann.

Entgegen der Ansicht der Beklagtenseite kann die Kammer dem Merkmal 1.2.2 (Versatz des „rotating menu" aus der Bildschirmmitte) nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Technizität absprechen. Wie bereits oben ausgeführt behandelt das Klagepatent ein Kapazitätsproblem, nämlich die Unterbringung einer Vielzahl von Optionen trotz beschränkter Kapazität auf einer

geschlossenen Menüanordnung, wie sie das nicht verschobene „rotating menu" darstellt. Es kann nicht mit der notwendigen Sicherheit verneint werden, dass es sich hierbei um die Lösung eines technischen Problems handelt, die auch mit technischen Mitteln erfolgt, nämlich durch eine Verschiebung.

B.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1, § 100 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Der Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten hat keinen Erfolg. Nach § 712 ZPO gestattet das Gericht auf Antrag, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden, wenn diese Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Das Vorliegen dieser tatsächlichen Voraussetzung hat die Beklagte weder dargetan noch - wie nach § 714 Abs. 2 ZPO erforderlich wäre - glaubhaft gemacht.

(...)	(...)	(...)
Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter

Verkündet am 25. Oktober 2016

_____

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle